DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 01-2023-MDCPO-CECARD/AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje Ordinario.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Consorcio Ayacucho.

Demandado : Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado – PRIDER.

TRIBUNAL UNIPERSONAL : Abg. María del Carmen Padilla Ortega – Árbitro Único.

SECRETARIA ARBITRAL : Bach. Katherine Sheyla Flores Martínez.

MATERIA DE CONTROVERSIA : Resolución de Contrato y otros.

FECHA DE SOLICITUD : 05 de enero de 2023.

FECHA DE INSTALACION : 28 de febrero de 2023.

FECHA DE EMISION DE LAUDO : 08 de marzo de 2024.

ESCRITOS POST LAUDO : Exclusión de Laudo.

Centro de Conciliacion Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

EXP. N° 01-2023-MDCPO-CARD-CECARD/AYA

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD
RECIBIDO
08 MAR 2024
N° de Registro: 88 N° de Folios: 58
Hora: 17:15 Firma:
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

ARBITRAJE INSTITUCIONAL

CONSORCIO AYACUCHO

vs.

PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO (PRIDER)

LAUDO ARBITRAL

ÁRBITRA ÚNICA

María del Carmen Padilla Ortega

Ayacucho, 08 de marzo de 2024.

CUADRO DE TÉRMINOS EMPLEADOS EN LA PRESENTE DECISIÓN

CONSORCIO o **Demandante**	CONSORCIO AYACUCHO
PRIDER, Entidad o **Demandado**	PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO
Partes	Se refiere conjuntamente a "CONSORCIO" y "PRIDER".
CENTRO	Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas CECARD.
REGLAMENTO	Reglamento de arbitraje del CENTRO.
Contrato	Contrato N° 032-2022-GRA-PRIDER/DG para el Servicio de extracción, apilamiento, transporte, conformación de enrocado y filtros en cuerpo de presa, incl. excavación para el cimiento, para la obra: Construcción del sistema de irrigación – represa Pallcca en el Distrito de Quinua – Huamanga – Ayacucho.
Convenio Arbitral	Acuerdo contenido en la cláusula décima octava del Contrato, por el que las Partes deciden someter a arbitraje sus controversias derivadas del mismo.
Árbitra Única	Árbitra Única designada por el CENTRO, que integra el Tribunal Arbitral Unipersonal, constituido para resolver la controversia.
LCE	Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley 30225, modificada por el Decreto Legislativo 1341, el Decreto Legislativo 1444 y la Ley Nº 31433 (vigente al 30.05.2022, a la fecha de convocatoria del contrato materia de controversia)
RLCE	Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, el Decreto

	Supremo N° 68-2020-EF, el Decreto Supremo N° 250-2020-EF, el Decreto Supremo N° 162-2022-EF (vigente al 30.05.2022, a la fecha de convocatoria del contrato materia de controversia)
Ley de Arbitraje	Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

RESOLUCIÓN N° 21

El presente documento constituye el laudo final emitido por la Árbitra Única, en el marco del proceso arbitral iniciado por el CONSORCIO contra el PRIDER, Expediente N° 01-2023-MDCPO-CARD-CECARD/AYA, con relación a las controversias surgidas en el Contrato N° 032-2022-GRA-PRIDER/DG.

I. MARCO INTRODUCTORIO.

1.1. Identificación de las Partes[1].

1. Son Partes de este arbitraje:

	Demandante	Demandado
Razón social:	CONSORCIO AYACUCHO conformado por Constructores y Consultores García S.A.C. y Empresa Constructora Mijers S.R.L..	PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO
Domicilio:	Urb. Maria Parado de Bellido Mz. H Lote 01 Emadi, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.	Av. Evitamiento N° 200, distrito de Jesús Nazareno – Huamanga-Ayacucho.
Correo electrónico:	cons_garcia@hotmail.com constructoragarciasac@gmail.com	Ori.63@hotmail.com Procursaduriaarbitraje2020@gmail.com [2]
Representante:	Teófilo Abilio García De la Cruz	Víctor Oriundo Medina, Procurador Público Regional a cargo de la defensa de los derechos e intereses del Gobierno Regional de Ayacucho.
Abogados:	Abg. Julio Hernán Salazar Morales	Abg. Ellie Huamani Huamani

[1] Según información que figura en el Contrato y, de los escritos presentados por las Partes en el caso.
[2] Direcciones precisadas mediante escrito de fecha 26.01.2024, presentado por el PRIDER.

1.2. Origen de la relación jurídica entre las Partes.

2. La relación jurídica que vincula a las Partes se ubica en el Contrato N° 032-2022-GRA-PRIDER/DG (el "Contrato"), celebrado con fecha 11 de agosto de 2022.

1.3. Tribunal Arbitral Unipersonal

3. El Tribunal Arbitral Unipersonal recae en la abogada María del Carmen Padilla Ortega, quién fue designada Árbitra Única por el CENTRO, para resolver las controversias surgidas entre las Partes, con relación al Contrato.

4. El Tribunal Arbitral unipersonal se tuvo por constituido a la aceptación de la Árbitra Única, efectuada con fecha 14 de febrero de 2023, no habiendo ninguna de las Partes presentado recusación alguna en contra de su nombramiento.

1.4. Cláusula arbitral.

5. Conforme a lo advertido de la solicitud arbitral presentada por el demandante con fecha 05 de enero de 2023, el inicio del presente proceso se funda en el Convenio Arbitral contenido en el Contrato, que se lee a continuación:

> **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**
> Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
>
> Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
>
> Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
>
> El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

6. El Convenio Arbitral no encomienda la organización y administración del arbitraje a una institución arbitral específica; por lo que de acuerdo con el literal b) del numeral 226.2

del artículo 226 del RLCE[3], el arbitraje puede ser iniciado ante cualquier institución arbitral.

7. En ese sentido, se verifica el acuerdo de las Partes de resolver todas las controversias derivadas de la ejecución del Contrato mediante arbitraje, pudiendo iniciarse este mecanismo ante cualquier institución arbitral, como lo es el CENTRO, el cual es competente para analizar la controversia del proceso.

1.5. Reglas procesales aplicables.

8. Las reglas del proceso fueron establecidas en la Resolución N° 1, la cual incluye las reglas contenidas en el REGLAMENTO del CENTRO.

1.6. Normativa aplicable al fondo de la controversia

9. Conforme a la cláusula décima séptima del Contrato, las Partes han establecido que sólo en lo no previsto en el contrato, comprende la Ley de Contrataciones del Estado ("LCE") y su Reglamento ("RLCE"), las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, siendo de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

1.7. Principales Actuaciones Arbitrales

10. Con fecha 05 de enero de 2023, el CONSORCIO presentó la solicitud de arbitraje, la misma que fue tramitada por el CENTRO y respondida por el PRIDER con fecha 20 de enero de 2023.

11. Mediante Resolución N° 01 de fecha 28 de febrero de 2023, se declaró instalado el Tribunal Arbitral Unipersonal, y se fijaron las reglas del proceso arbitral; asimismo, se otorgó a las Partes un plazo de cinco (05) días para que formulen alguna propuesta de modificación y/o observación contra las reglas del arbitraje, precisándose que transcurrido dicho plazo sin que se presenten comentarios u observaciones, se entenderán que están conformes con las mismas. De igual manera, a través de dicha resolución, se otorgó a la Entidad el plazo de die (10) días, para que acredite el registro de los datos del Tribunal Arbitral y la secretaria arbitral en el SEACE, así como para que remita la solicitud a la Contraloría General de la República del Perú a fin de que se habilite a la Árbitro Único para formular su Declaración Jurada de Intereses en el presente arbitraje.

[3] De acuerdo con el literal b) del numeral 226.2 del artículo 226 del RLCE, el arbitraje es iniciado ante cualquier institución arbitral, cuando a pesar de haberse precisado en el convenio arbitral que el arbitraje es institucional, no se ha designado a una institución arbitral determinada.

12. Mediante Resolución N° 02 de fecha 8 de marzo de 2023, el Tribunal Arbitral Unipersonal resolvió entre otros, fijar en forma definitiva las reglas del proceso; asimismo, le otorgó al CONSORCIO el plazo de diez (10) días hábiles, a fin de que presente su escrito de demanda.

13. Mediante Resolución N° 03 de fecha 27 de marzo de 2023, el Tribunal Arbitral Unipersonal resolvió, entre otros: (i) Admitir la demanda arbitral presentada por el CONSORCIO; (ii) Correr traslado de la demanda arbitral y los medios probatorios que la acompañan al PRIDER, para que en un plazo de diez (10) días hábiles cumpla con contestarla, y de considerarlo conveniente formule reconvención; (iii) Otorgar a las partes el plazo de cinco (05) días hábiles, a fin de que cumplan con acreditar el cumplimiento del pago de los honorarios arbitrales, bajo apercibimiento de suspender el arbitraje; (iv) Otorgar al PRIDER el plazo final de diez (10) días hábiles, a fin de que cumpla con registrar los nombres y apellidos del Árbitro Único en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- SEACE.

14. Mediante Resolución N° 04 de fecha 18 de abril de 2023, el Tribunal Arbitral Unipersonal resolvió, entre otros: (i) Suspender las actuaciones arbitrales por el plazo de veinte (20) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84° del Reglamento del CENTRO; (ii) Tener por cumplido por la Entidad el registro de los nombres de la Árbitra única y de la secretaria arbitral en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado -SEACE; (iii) Tener por presentada la contestación de la demanda, por la Procuraduría Regional de Ayacucho, asimismo, se dejó constancia que dicho escrito permanecería en custodia de la secretaria arbitral y sería tramitado una vez que se levante la suspensión del arbitraje.

15. Mediante Resolución N° 5 de fecha 24 de mayo de 2023, el Tribunal Arbitral Unipersonal otorgó al CONSORCIO el plazo excepcional de diez (10) días hábiles, a fin de que cumpla con el pago de los honorarios arbitrales y gastos administrativos; asimismo, suspendió el proceso por diez (10) días hábiles, precisando que, transcurrido el plazo de suspensión del arbitraje sin que se verifique el pago por alguna de las Partes, la Árbitro Único podrá disponer el archivo de las actuaciones arbitrales.

16. Mediante Resolución N° 6 de fecha 13 de junio de 2023, el Tribunal Arbitral Unipersonal tuvo por cumplido el pago de los honorarios de la arbitra única, respecto a la fracción que le corresponde al CONSORCIO; asimismo, dispuso el levantamiento de la suspensión arbitral, y admitió a trámite la contestación arbitral presentada por el PRIDER.

17. Mediante Resolución N° 7 de fecha 19 de junio de 2023, el Tribunal Arbitral Unipersonal tuvo por cumplido el pago de los gastos administrativos, respecto a la fracción que le corresponde al CONSORCIO; asimismo, fijó las cuestiones controvertidas del arbitraje y admitió los medios probatorios ofrecidos por el CONSORCIO en su escrito de

demanda, dejando constancia que el PRIDER no ofreció medios de prueba. Las cuestiones controvertidas determinadas fueron las siguientes:

i. Primera cuestión controvertida referida a la Primera Pretensión Principal:

Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no declarar la invalidez y/o ineficacia de la resolución parcial del Contrato N° 032-2022-GRA-PRIDER/DG, efectuado por la Entidad mediante Carta Notarial N° 80-2022-GRA-GG/PRIDER-DG, de fecha 12 de diciembre de 2022.

ii. Segunda cuestión controvertida referida a la Segunda Pretensión Principal:

Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no ordenar al Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural de Ayacucho el pago pendiente a favor del Consorcio Ayacucho por la prestación efectivamente ejecutada a favor de la Entidad, por la suma de S/ 438,209.90 (Cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos nueve con 89/100 soles).

iii. Tercera cuestión controvertida referida a la Pretensión Subordinada a la Segunda Pretensión Principal:

De no admitirse la Segunda Pretensión Principal, que el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no ordenar al Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural de Ayacucho el pago de la suma de S/ 438,209.90 (Cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos nueve con 90/100 soles), como reparación por el daño emergente ocasionado al Consorcio Ayacucho.

iv. Cuarta cuestión controvertida referida a la Tercera Pretensión Principal:

De no admitirse la Segunda Pretensión Principal ni la Pretensión Subordinada a la Segunda Pretensión Principal, que el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no determinar el metrado realmente ejecutado por el Consorcio Ayacucho en la prestación del servicio de extracción, apilamiento, transporte, conformación de enrocado y filtros en cuerpo de presa, incl. excavación para el cimiento, para la obra: construcción del sistema de irrigación -represa Pal/cea en el Distrito de Quinua -Huamanga -Ayacucho, conforme al sistema de contratación, hasta el 12 de diciembre de 2022 y, consecuentemente, si corresponde determinar el saldo económico pendiente de pago a favor del Consorcio.

v. Quinta cuestión controvertida referida a la Cuarta Pretensión Principal:

Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no considerar como justificado los retrasos incurridos por el consorcio en la prestación del servicio y, consecuentemente, ordenar a PRIDER, la devolución del monto

retenido por la Entidad como garantía de fiel cumplimiento para la ejecución del Contrato N° 032-2022-GRAPRIDER/DG.

Asimismo, mediante dicha decisión, se otorgó al CONSORCIO el plazo de cinco (05) días para que informe sobre la presentación del informe denominado "VALORIZACIÓN FINAL DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN, APILAMIENTO, TRANSPORTE, CONFORMACIÓN DE ENROCADO Y FILTRO DE CUERPO DE PRESA, INCL. EXCAVACIÓN PARA EL CIMIENTO, PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE IRRIGACIÓN - REPRESA PALLCCA EN EL DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA- AYACUCHO", bajo apercibimiento de prescindir del mismo.

18. Mediante Resolución N° 8 de fecha 6 de julio de 2023, el Tribunal Arbitral declaró consentidos los puntos controvertidos determinados en la Decisión N° 7; de igual forma, tuvo por ofrecido como medio probatorio el informe técnico denominado *"Valorización Final Del Servicio De Extracción, Apilamiento, Transporte, Conformación De Enrocado Y Filtro De Cuerpo De Presa, Incl. Excavación Para El Cimiento, Para La Obra "Construcción De Sistema De Irrigación - Represa Pallcca En El Distrito De Quinua - Huamanga- Ayacucho"*, otorgándole el plazo de diez (10) días hábiles a fin de que cumpla con presentarla, bajo apercibimiento de prescindirse de dicha prueba. Asimismo, mediante Resolución N° 8, el Tribunal Arbitral exhortó a la ENTIDAD a brindar las facilidades para la entrega de los datos requeridos por el CONSORCIO, con relación al levantamiento topográfico de fecha 20 de junio; igualmente otorgó al CONSORCIO el plazo de cinco (05) días hábiles, a fin de que cumpla con acreditar el cumplimiento del pago de los honorarios arbitrales que le fueron subrogados, bajo apercibimiento de suspender el arbitraje en el estado en que se encuentra.

Centro de Conciliación y Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

19. Mediante Resolución N° 9 de fecha 25 de julio de 2023, el tribunal Arbitral Unipersonal dejó constancia que el CONSORCIO no ha cumplido con presentar el informe técnico titulado "Valorización Final Del Servicio De Extracción, Apilamiento, Transporte, Conformación De Enrocado Y Filtro De Cuerpo De Presa, Incl. Excavación Para El Cimiento, Para La Obra 'Construcción De Sistema De Irrigación - Represa Pallcca En El Distrito De Quinua - Huamanga – Ayacucho"; en consecuencia, se dispuso, prescindir de dicho elemento probatorio. Asimismo, mediante la Resolución N° 9, se dejó constancia la falta de pago de los honorarios profesionales de la Árbitra Única y los gastos administrativos subrogados, a cargo del CONSORCIO, y se dispuso la suspensión de las actuaciones arbitrales por el plazo de veinte (20) días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84° del Reglamento del CENTRO.

20. Mediante Decisión N° 10 de fecha 04 de setiembre de 2023, el Tribunal Arbitral Unipersonal tuvo por cumplido el pago de los honorarios, que fueron subrogados al CONSORCIO; asimismo levantó la suspensión arbitral, y otorgó al CONSORCIO el plazo adicional de cinco (05) días hábiles a fin de que cumpla el pago de los gastos administrativos. Igualmente, a través de la Decisión N° 10 concedió el Recurso de

Reconsideración contra la Resolución N°9 presentada por el CONSORCIO y, en consecuencia, requirió al PRIDER presentar los resultados obtenidos en la constatación del día 20 de junio de 2023, respecto al avance ejecutado por el CONSORCIO, en el plazo de diez (10) días hábiles. Del mismo modo, corrió traslado al PRIDER para que en el plazo de cinco (05) días hábiles cumpla con manifestar lo conveniente a su derecho respecto del Informe de valorización mensual de obra N°04 (correspondiente al mes de noviembre de 2022), presentado por el CONSORCIO.

21. Mediante Decisión N° 11 de fecha 18 de setiembre de 2023, el Tribunal Arbitral Unipersonal otorgó al PRIDER el plazo de cinco días hábiles a fin de que cumpla con absolver el Informe de valorización mensual de obra N°04 trasladada mediante la Resolución Nro. 10; asimismo, tuvo por cumplido por parte del CONSORCIO, la totalidad del pago de los gastos administrativos.

22. Mediante Decisión N° 12 de fecha 29 de setiembre de 2023, el Tribunal Arbitral Unipersonal otorgó al PRIDER el plazo final de cinco (05) días hábiles a fin de que cumpla con presentar los resultados obtenidos en la constatación del día 20 de junio de 2023, respecto al avance ejecutado por el CONSORCIO, bajo apercibimiento de tener en cuenta su conducta procesal al momento de emitir el Laudo arbitral; de igual manera, se instó a las partes, procurar la celeridad de las actuaciones arbitrales.

23. Mediante Decisión N° 13 de fecha 16 de octubre de 2023, el Tribunal Arbitral Unipersonal *dejó constancia que el PRIDER no ha cumplido con la presentación de los resultados obtenidos en la constatación del día 20 de junio de 2023, por lo que se tendrá en cuenta su conducta procesal; asimismo, se dejó constancia que la Entidad no cumplió con absolver *El informe de valorización mensual de obra N°04 (correspondiente al mes de noviembre de 2022)* pese al plazo adicional concedido, teniéndose en cuenta su conducta procesal. Asimismo, a través de la Decisión N° 13, se citó a las partes a Audiencia Única, dejándose constancia que la demora en las actuaciones arbitrales obedece al accionar de las partes, por lo que se les instó a procurar la celeridad de las actuaciones arbitrales.

24. Mediante Decisión N° 14 de fecha 20 de octubre 2023, el Tribunal Arbitral Unipersonal tuvo presente el escrito de fecha 19 de octubre de 2023 presentado por el PRIDER, corriéndose traslado del mismo al CONSORCIO, a efectos de que en el plazo de cinco (05) días hábiles cumpla con manifestar lo conveniente a su derecho.

25. Mediante Decisión N° 15 de fecha 03 de noviembre de 2023, el Tribunal Arbitral Unipersonal tuvo presente el escrito de fecha 31 de octubre de 2023 presentado por el CONSORCIO, con conocimiento de su contraparte. Asimismo, corrió traslado del escrito de fecha 19 de octubre de 2023, presentado por la Procuraduría Pública Regional de Ayacucho, al CONSORCIO a efectos de que en el plazo de cinco (05) días hábiles cumpla con manifestar lo conveniente a su derecho.

26. Mediante Decisión N° 16 de fecha 08 de noviembre de 2023, el Tribunal Arbitral Unipersonal tuvo presente el escrito de fecha 06 de noviembre de 2023 presentado por el PRIDER, en conocimiento de su contraparte; asimismo, tuvo presente el escrito de fecha 07 de noviembre de 2023 presentado por el CONSORCIO, con conocimiento de su contraria.

27. Con fecha 08 de noviembre de 2023, se llevó a cabo la Audiencia Única, con participación de las Partes, conforme consta en el acta respectiva.

28. Mediante Decisión N° 17 de fecha 14 de noviembre de 2023, el Tribunal Arbitral Unipersonal tuvo presente tuvo presente las diapositivas presentadas por el CONSORCIO, con conocimiento de su contraria; asimismo, declaró cerrada la etapa probatoria del presente proceso arbitral, dejando constancia que ninguna de las partes podrá presentar medio probatorio alguno, salvo que el Árbitro Único requiera de oficio la actuación de pruebas adicionales que considere conveniente.

29. Mediante Decisión N° 18 de fecha 5 de enero de 2024, el Tribunal Arbitral Unipersonal tuvo presente los escritos de alegatos presentados por las partes, con conocimiento de su contraria correspondiente; asimismo, declaró cerrada las actuaciones arbitrales y fijó el plazo para emitir el Laudo en treinta (30) días hábiles.

30. Mediante Decisión N° 19 de fecha 29 de enero de 2024, el Tribunal Arbitral Unipersonal tuvo presente el escrito de fecha 26 de enero de 2024, presentado por el PRIDER; asimismo, tuvo por modificados los correos electrónicos habilitados para notificaciones y comunicaciones por parte de la ENTIDAD.

31. Mediante Decisión N° 20 de fecha 15 de febrero de 2024, el Tribunal Arbitral Unipersonal amplió el plazo fijado para laudar, por el termino de quince (15) días hábiles adicionales, precisándose que el cómputo de dicho plazo empezará el día lunes 19 de febrero de 2024, en atención a que los días 17 y 18 son días inhábiles (sábado y domingo, respectivamente).

32. Por lo que, habiendo tenido ambas partes oportunidad razonable para sustentar lo conveniente a su derecho respecto de las pretensiones planteadas por la parte demandante, de conformidad con las Reglas aplicables y el REGLAMENTO y dentro del plazo establecido, corresponde la Árbitra Única pronunciarse sobre las mismas.

II. ANÁLISIS DEL CASO

2.1. Cuestiones Preliminares

33. Como cuestión preliminar, se estima importante señalar, lo siguiente:

(i) La Árbitra Única fue designada por el Centro, habiéndose constituido el Tribunal Arbitral unipersonal con su aceptación correspondiente, de acuerdo con el Convenio Arbitral y la normativa vigente;

(ii) Mediante Resolución N° 1, la Árbitra Única estableció las Reglas Aplicables al proceso, no habiendo las partes formulado observación ni cuestionamiento alguno, por lo que tales reglas han quedado firmes, habiendo desarrollado las actuaciones procesales con sujeción a las mismas y al Reglamento del CENTRO.

(iii) De acuerdo con las Reglas Aplicables, el CONSORCIO presentó su escrito de demanda, dentro del plazo correspondiente;

(iv) Del mismo modo, el PRIDER presentó su escrito de contestación a la demanda dentro del plazo establecido en las Reglas Aplicables.

(v) La Árbitra Única ha ordenado las actuaciones, contemplando la realización de una Audiencia Única.

(vi) Las partes han tenido plena oportunidad para formular sus alegaciones respecto a las pretensiones planteadas (tanto escritas como oralmente), así como para ofrecer y actuar todos los medios probatorios que consideren pertinentes para su defensa, no existiendo ningún asunto pendiente que resolver.

(vii) Habiéndose actuadas las pruebas y escuchado a las Partes, la Árbitra Única procedió a declarar el cierre de las actuaciones arbitrales y se fijó el plazo para laudar mediante la Resolución N° 18, siendo este prorrogado por quince (15) días hábiles adicionales, mediante Resolución N° 20.

(viii) En ese sentido, se procede a laudar dentro del plazo correspondiente aplicable, de acuerdo con las Reglas Aplicables y el REGLAMENTO.

Centro de Conciliación y Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

34. Del mismo modo, se estima pertinente indicar que, la tramitación del presente proceso se ha llevado a cabo con estricta sujeción al debido proceso y las Reglas Aplicables, habiéndose respetado el derecho de las partes a sustentar su caso, y a exponer de forma escrita y oral sus alegaciones y conclusiones.

4.1. Materia controvertida

35. La materia controvertida sometida a arbitraje ha sido determinada por la Árbitra Única mediante la Resolución N° 7 fecha 19 de junio de 2023.

36. Por lo que, se precisa que el análisis siguiente se circunscribe únicamente a dichos puntos controvertidos.

4.3. **Valoración de las Pruebas**

37. Para el análisis, evaluación y resolución del presente caso, la Árbitra Única precisa que ha considerado en conjunto todos los planteamientos, fundamentos, alegaciones y, pruebas aportadas oportunamente por las partes al expediente, dejando constancia que ambas partes tuvieron plena libertad para ofrecer todos los

medios probatorios que estimaron convenientes para fundamentar sus posiciones, sin que haya existido limitación de ninguna clase.

38. Asimismo, se estima importante precisar para efectos del análisis de las pretensiones, se ha prestado especial atención al principio general que "quien alega un hecho debe probarlo". Dicho principio deriva de la responsabilidad que tiene la parte que pretende que se declare un derecho, de aportar los medios probatorios que sustenten y acrediten la existencia de ese derecho; pues de lo contrario, su pretensión carecerá de sustento y, por ende, deberá ser desestimada.

39. Tanto en jurisdicción ordinaria o arbitral, rige el principio de carga de la prueba establecido por el artículo 196 del Código Procesal Civil, el cual contempla que, salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos. Por lo que, el análisis de los puntos controvertidos siguientes ha tenido en cuenta, el sustento de prueba actuado por cada parte para fundamentar sus alegaciones.

40. De este modo, la carga de la prueba recaerá en quien alega los hechos. Argumentar lo contrario implicaría una vulneración flagrante del derecho al debido proceso, ya que obligaría a una de las partes a probar los hechos alegados por su contraparte, colocándolo en una evidente situación de desventaja. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado:

> "37. Se ha señalado, igualmente, que dicho derecho comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal y que, en ese sentido, se trata de un derecho "continente". En efecto, su contenido constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, cuyo cumplimiento efectivo garantiza que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre comprendida una persona pueda considerarse como justo."
>
> [STC N° 6149-2006-PA/TC Y 6662-2006-PA/TC]

41. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional agrega lo siguiente:

> "5. El derecho de igualdad procesal o de igualdad de armas se deriva de la interpretación sistemática del artículo 2, inciso 2, (igualdad) y del artículo 138, inciso 2 (debido proceso), de la Constitución. En tal sentido, todo proceso, judicial, administrativo o en sede privada, debe garantizar que las partes del proceso detenten las mismas oportunidades de alegar, defenderse o probar, de modo que no se ocasione una desventaja en ninguna de ellas respecto a la otra. Tal exigencia constituye un componente del debido proceso ya que ningún proceso que inobserve dicho imperativo puede reputarse como "debido"."
>
> [STC N° 06135-2006-PA/TC]

42. En buena cuenta, el salvaguardar las reglas de carga probatoria implica respetar el contenido constitucionalmente protegido del derecho al debido proceso, dado que, de este modo, se cautela el derecho a la igualdad procesal.

43. Por otro lado, debe indicarse que el Tribunal Arbitral ha tenido en cuenta el conjunto de alegaciones y fundamentos presentados oportunamente por las partes, debiendo señalarse que la no mención de alguna alegación o fundamento presentados por las partes, no implicará que la Árbitra Única no lo haya tenido en cuenta ni sopesado para el análisis del caso, reconociéndose que la práctica arbitral reconoce que para un resolución motivada los árbitros no están obligados a exponer todos y cada uno de los argumentos planteados por las partes.

44. De igual manera se precisa que, la no referencia a un argumento o a una prueba aportada en el proceso, no supone que no se haya tenido en cuenta para su decisión, pues de conformidad con el artículo 43° de la Ley de Arbitraje, el Tribunal Arbitral Unipersonal tiene la facultad para determinar de manera exclusiva la admisión, pertinencia, actuación y valor de las pruebas, estando facultado a prescindir motivadamente de las pruebas ofrecidas y no actuadas, según las circunstancias del caso.

45. De igual forma, cabe mencionar que la actividad probatoria se sustenta en el principio de adquisición procesal, el cual consiste en que las pruebas de una de las partes pueden resultar benéficas a los intereses de la contraria y, más aún, el juzgador ha de examinar y valorar las pruebas que obran en autos, a fin de obtener con esos medios de prueba la verdad histórica que debe prevalecer en el caso justiciable.

46. Bajo estas consideraciones expuestas, el Tribunal Arbitral Unipersonal procede a emitir su pronunciamiento respecto al presente caso arbitral, de acuerdo al marco legal aplicable al contrato, el cual según la cláusula décima sétima de dicho documento, establece que: "Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, será de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado."

47. Por lo que, a continuación, se procede al análisis de los puntos controvertidos del caso, con sujeción al marco contractual y normativo aplicable.

4.1. Fundamentación de los puntos controvertidos

a) Fundamentación de la Primera Cuestión Controvertida

48. El punto controvertido que se procede a analizar es el siguiente:

i.	**Primera cuestión controvertida referida a la Primera Pretensión Principal:** Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no declarar la invalidez y/o ineficacia de la resolución parcial del Contrato Nº 032-2022-GRA-PRIDER/DG, efectuado por la Entidad mediante Carta Notarial Nº 80-2022-GRA-GG/PRIDER-DG, de fecha 12 de diciembre de 2022.

Posición del CONSORCIO

49. El CONSORCIO sustenta su posición, relatando los siguientes hechos:

- Mediante Carta Notarial N° 60-2022-GRA-GG/PRIDER-DG, PRIDER le requirió el cumplimiento de sus obligaciones por no contar con el personal clave y maquinarias ofertadas, otorgándole un plazo de 03 días calendarios, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

- Mediante N° 021-2022-CONS-AYACUCHO/RC, el CONSORCIO absolvió los incumplimientos detallados en la Carta de apercibimiento, adjuntando el Informe N° 005-2022-ATDR/JB, que mencionaba que el Consorcio venía realizando labores en distintas partes de la obra, estando algunos en cantera y otros realizando trámites administrativos en el PRIDER y SUCAMEC.

- Mediante Carta Notarial N° 72-2022 GRA-GG/PRIDER-DG de fecha 14 de noviembre de 2022, el PRIDER comunicó al CONSORCIO que estaría incumpliendo sus obligaciones contractuales, incurriendo en penalidades, de conformidad a lo previsto en la cláusula décimo tercera del Contrato.

- Mediante Carta N° 021-2022-CONS-AYACUCHO/RC de fecha 18 de noviembre de 2022, el CONSORCIO presentó sus descargos a las imputaciones de la Entidad, reiterando que, para el cumplimiento del servicio, era necesario que parte del personal ofertado y maquinarias se encuentren en lugares distintos donde se viene ejecutando la obra, por cuanto también su obligación era producir materiales en cantera (M6 y M7). Ante ello, solicitaron que, en lo posterior, realicen las constataciones en todos los lugares de intervención por el Consorcio Ayacucho.

- Debido a los problemas surgidos por la producción del M8 (ya que no era obligación del consorcio su producción), mediante Carta S/N, diligenciado por el Notario Público Mario Almonacid Cisneros, el CONSORCIO requirió a la Entidad que, en un plazo no mayor de 05 días, cumpla con su obligación esencial de disponer en obra el material tipo M8, a fin de poder realizar la "conformación de enrocado de protección" de este material, bajo apercibimiento de resolver el

contrato. Asimismo, el CONSORCIO señaló que al no contar con frente de trabajo (por la falta del material M8 en campo) era imposible continuar con la prestación del servicio.

- Mediante Carta Notarial N° 80-2022-GRA-GG/PRIDER-DG, de fecha 12 de diciembre de 2022, PRIDER comunicó la resolución parcial del contrato por incumplimiento de obligaciones esenciales, haciendo referencia a un contrato distinto al suscrito por las partes.

50. En ese sentido, la parte demandante sustenta su pretensión en los siguientes fundamentos:

- El apercibimiento realizado mediante Carta Notarial N° 72-2022-GRA-GG/PRIDER-DG y Carta Notarial N° 72-2022-GRA-GG/PRIDER-DG, fueron subsanadas oportunamente.

- En la carta de apercibimiento remitida a la Entidad del 05 de diciembre de 2022, el CONSORCIO manifestó que, a esa fecha, no contábamos con el material M8 para poder realizar "la conformación de enrocado de protección.

- Al 07 de diciembre de 2022, era justificado la ausencia del personal ofertado por el consorcio, pues no se tenía frente de trabajo, por lo que el CONSORCIO suspendió la ejecución del servicio hasta que la Entidad cumpla con su obligación esencial de disponer en obra el material de tipo M8; ya que nos resultaba más oneroso el mantener al personal en campo sin que realice ningún tipo de actividades.

- A través de las comunicaciones realizadas el Consorcio ha demostrado que el personal clave ofertado y parte de las maquinarias se encontraban fuera del lugar de ejecución de la obra debido a que se venían realizando labores distintas, como, por ejemplo, la producción de material, para la realización del enrocado en el cuerpo de presa.

- De acuerdo con la Opinión N° 083-2021/DTN, la segunda carta notarial mediante la cual la Entidad decide la resolución del contrato debe versar sobre la misma situación de incumplimiento que no fue revertida por el contratista pese a haber sido requerido para ello, tal como establece el literal a) del numeral 164.1 del artículo 164 del Reglamento.

Posición del PRIDER

51. Por su parte, el PRIDER absuelve la pretensión, en base a los siguientes fundamentos:

- El CONSORCIO sustenta su posición en que era imposible continuar con la prestación a raíz del incumplimiento de las obligaciones esenciales de la entidad de proveer material tipo M8; sin embargo, de los medios de prueba adjuntos, ninguno acredita fehacientemente que la provisión O suministro del material era una obligación esencial de la entidad;

- Por el contrario, el CONSORCIO admite que efectivamente no estaban prestando el servicio; señalando que lo suspendieron cuando ni la ley ni el reglamento han establecido una posible suspensión unilateral de las prestaciones en los contratos de servicio como sí está previsto en los contratos de obra, quedando evidenciado que el demandante ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones y que ha vulnerado las normas de la materia.

- La resolución del contrato no ha seguido el procedimiento formal por no haberle otorgado expresamente en la carta reiterativa de requerimiento el plazo legal para ejecutar sus obligaciones; sin embargo, reconoce que en la primera carta de apercibimiento si se precisó el plazo, y que dicho requerimiento ya había habilitado el derecho de la entidad de resolver el contrato en caso persista el incumplimiento de las obligaciones del contratista.

- La entidad, salvaguardando el cumplimiento del objeto contractual, reitera el cumplimiento de las obligaciones que han generado como respuesta descargos en los que se comprueba el incumplimiento de las obligaciones, pues, confirman la ausencia del personal, por permisos personales no comunicados a la entidad ni contemplados en la norma, y la inoperatividad de la maquinaria; por lo que no se puede considerar estos descargos como sinónimo de cumplimiento de las obligaciones requeridas conforme a la normativa de la materia.

Centro de Conciliación y Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

<u>Posición del Tribunal Arbitral Unipersonal</u>

52. De los actuados del caso, consta que el PRIDER mediante la Carta Notarial N° 080-2022-GRA-GG/PRIDER-DG de fecha 12 de diciembre de 2022 (en adelante "la Carta Resolutoria"), comunicó la resolución parcial del Contrato por la <u>causal de incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales vinculadas a la ausencia del personal y maquinaria ofertada,</u> pese a haberse requerido para ello.

53. En tal sentido, el presente análisis comprenderá la evaluación acerca de si la decisión adoptada por la Entidad a través de la Carta Resolutoria cumplió con los requisitos, exigencias y formalidades establecidos en la normativa aplicable para su validez y eficacia, pues solo en la medida que estos aspectos hayan sido cumplidos en el marco del ejercicio de la función administrativa del Estado podrá reconocerse sus efectos legales, de acuerdo a lo dispuesto en la Quinta Disposición Complementaria

Final de la LCE.[4]

54. De acuerdo con el marco legal del Contrato, en específico a la cláusula décima cuarta: "*Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, la ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.*"

55. De la lectura conjunta del numeral 32.3 del artículo 32 y el artículo 36 de la LCE, así como del artículo 164 de la LCE, se desprende que cualquiera de las partes podrá resolver el contrato por incumplimiento, conforme a los supuestos y al procedimiento contemplados en el Reglamento.

56. A continuación, se cita el texto de los artículos aplicables al procedimiento de resolución del contrato por incumplimiento:

> ***Artículo 32. el contrato***
> *(…)*
> *32.3 Los contratos regulados por la presente norma incluyen necesariamente y bajo responsabilidad las cláusulas referidas a: a) Garantías, b) Anticorrupción, c) Solución de controversias y d) Resolución de contrato por incumplimiento, conforme a lo previsto en el reglamento.*
> *(…)*
>
> ***Artículo 36. resolución de los contratos***
> *36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.*
> *36.2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el artículo 11.*
>
> ***Artículo 164. Causales de resolución***
> *164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:*
> *a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;*

[4] De acuerdo con el criterio de la Opinión N° 080-2020/DTN que en virtud de la decisión de ejecución de garantía por una Entidad señala que "(…) se trata de una expresión de la "voluntad de la Administración", debe encontrarse debidamente sustentada al interior de la Entidad, conforme a lo establecido por los principios generales que regulan el ejercicio de la Función Administrativa del Estado, así como, de acuerdo a lo dispuesto en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley."

b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o
c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
164.2. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el artículo 165.
164.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato.
164.3. En los contratos de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades del supervisor comprenden la liquidación del contrato de obra, el supervisor puede resolver el contrato en los casos en que existe una controversia que se derive de la liquidación del contrato de obra.
164.4. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato.

57. En el presente caso, la resolución del contrato efectuada mediante la Carta Resolutoria por el PRIDER se sustenta en el incumplimiento injustificado de las obligaciones a cargo del Contratista, causal identificada en el literal a) del numeral 164.1 del artículo 164 del RLCE, que considera como supuesto de resolución ***el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.***

58. En esa línea, el artículo 165 del RLCE desarrolla el procedimiento de resolución del contrato por incumplimiento, regulando las formalidades y condiciones que deberá cumplir dicho procedimiento de resolución, precisando en el numeral 165.1 que, la parte perjudicada deberá requerir mediante carta notarial a la otra para que las ejecute, otorgándole un plazo bajo apercibimiento de resolver el contrato:

Artículo 165. Procedimiento de resolución de contrato
165.1. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
165.2. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días. En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días.
165.3. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada

puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.

165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

165.5. Cuando la resolución se sustente en alguno de los supuestos establecidos en el numeral 164.4 del artículo 164, la parte que resuelve debe comunicar su decisión mediante carta notarial justificando y acreditando los hechos que la sustentan.

165.6. La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe precisa con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total.

165.7. Tratándose de contrataciones realizadas a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, toda notificación efectuada en el marco del procedimiento de resolución del contrato regulado en el presente artículo se realiza a través del módulo de catálogo electrónico. En estos casos, no es necesario comunicar la decisión mediante carta notarial.

59. Por lo que a continuación, la Árbitra Única procede a efectuar análisis formal sobre el cumplimiento del procedimiento de resolución contractual detallado en el artículo 165 del RLCE, y un análisis de fondo, referido a la existencia de la causal de resolución del contrato, invocada por la Entidad. Debe precisarse que el cumplimiento de ambos aspectos es determinante para la validez y eficacia de la Carta Resolutoria. De esta manera, si de la revisión de cualquiera de ellos (aspecto formal o de fondo), el Tribunal Arbitral Unipersonal determina que no ha sido cumplido por el PRIDER, no será necesario continuar con el análisis del otro aspecto pendiente, dado que la validez del procedimiento de resolución contractual exige el cumplimiento de ambos, de manera concurrente.

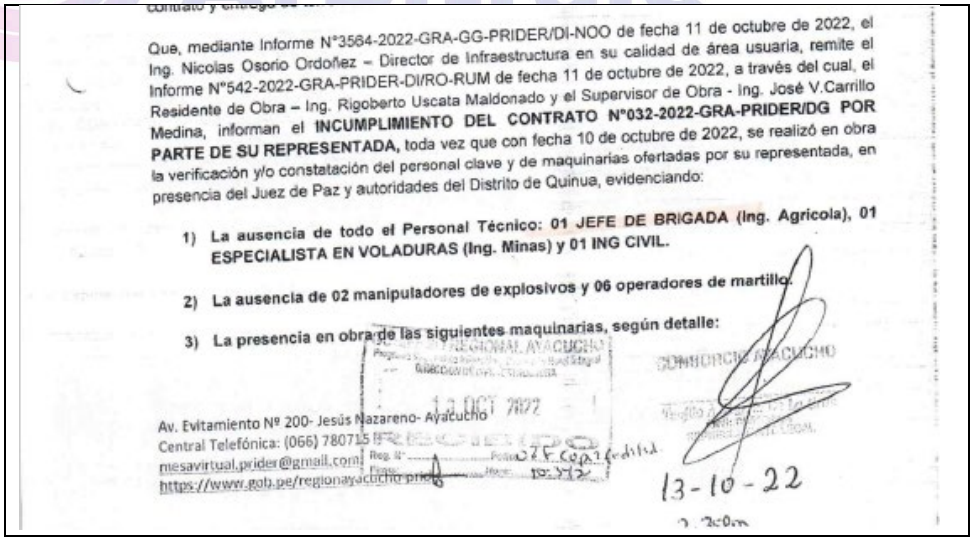
60. En ese sentido, se inicia el análisis con el aspecto formal del procedimiento, conforme al marco legal aplicable al contrato.

61. De acuerdo con los numerales 165.1, 165.2 y 165.3, es condición para resolver el contrato, que la parte afectada envíe una carta notarial requiriendo a la parte incumplidora que ejecute sus obligaciones, otorgándole un plazo bajo apercibimiento de resolver el contrato. Asimismo, de persistir el incumplimiento vencido el plazo concedido, la parte perjudicada podrá resolver el contrato,

comunicando su decisión carta notarial. Es partir de la recepción de esta comunicación de resolución del contrato, cumpliendo todas las formalidades y requisitos exigidos, que el contrato queda resuelto de pleno derecho.

62. En el caso de autos, la Árbitra Única advierte que la discusión entre las Partes se centra en el cumplimiento de las formalidades exigidas respecto al apercibimiento previo a la resolución contractual realizada por el PRIDER, pues existen dos comunicaciones notariales previas diligenciadas por la Entidad: (i) la Carta Notarial N° 060-2022-GRA-GG/PRIDER-DG de fecha 12 de octubre de 2022 (en adelante, Primera Carta Notarial), y (ii) La Carta Notarial N° 072-2022-GRA-GG/PRIDER-DG de fecha 14 de noviembre de 2022, (en adelante, Segunda Carta Notarial), siendo cuestionado por el demandante si ambas comunicaciones debían de cumplir la formalidad notarial establecida por el artículo 165 del RLCE para requerir el cumplimiento de obligaciones con motivo a una resolución contractual.

63. De la revisión de la Primera Carta Notarial con el asunto *"Requiero Cumplimiento de obligaciones contractuales – apercibimiento"*, se advierte que con fecha 12 de octubre de 2022 el PRIDER imputó al Contratista **el incumplimiento de sus obligaciones esenciales vinculadas a la presencia de su personal y maquinaria ofertada, requiriéndole el cumplimiento de sus obligaciones contractuales conforme a los TDR aplicables a la prestación del servicio materia de contrato y otorgándole un plazo de 3 días calendario para revertir dicha imputación, bajo apercibimiento de resolver el contrato:**



Que, mediante Informe N°3564-2022-GRA-GG-PRIDER/DI-NOO de fecha 11 de octubre de 2022, el Ing. Nicolas Osorio Ordoñez – Director de Infraestructura en su calidad de área usuaria, remite el Informe N°542-2022-GRA-PRIDER-DI/RO-RUM de fecha 11 de octubre de 2022, a través del cual, el Residente de Obra – Ing. Rigoberto Uscata Maldonado y el Supervisor de Obra - Ing. José V.Carrillo Medina, informan el **INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N°032-2022-GRA-PRIDER/DG POR PARTE DE SU REPRESENTADA,** toda vez que con fecha 10 de octubre de 2022, se realizó en obra la verificación y/o constatación del personal clave y de maquinarias ofertadas por su representada, en presencia del Juez de Paz y autoridades del Distrito de Quinua, evidenciando:

1) **La ausencia de todo el Personal Técnico: 01 JEFE DE BRIGADA (Ing. Agrícola), 01 ESPECIALISTA EN VOLADURAS (Ing. Minas) y 01 ING CIVIL.**
2) **La ausencia de 02 manipuladores de explosivos y 06 operadores de martillo.**
3) **La presencia en obra de las siguientes maquinarias, según detalle:**

Av. Evitamiento Nº 200- Jesús Nazareno- Ayacucho
Central Telefónica: (066) 780715
mesavirtual.prider@gmail.com
https://www.gob.pe/regionayacucho-pri

13-10-22

Fuente: Carta Notarial N° 060-2022-GRA-GG/PRIDER-DG,
ofrecida como medio probatorio de la demanda, por el CONSORCIO.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO - PRIDER

Prider

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

MAQUINARIA	CONDICION	OPERADOR
Excavadora sobre Oruga Marca CAT Modelo 324E	Malogrado	Sin Operador
Excavadora Sobre Oruga Marca HYUNDI Modelo 260LC – 95Robex	Operativo	Sin Operador
Excavadora Sobre Oruga Marca CAT Modelo 336D	Operativo	Flexman Ramos Rojas DNI 44037792
Excavadora Sobre Oruga Marca CAT Modelo 336D	Operativo	Sin Operador
Excavadora Sobre Oruga Marca HYUNDI Modelo 260LC – 95Robex	Operativo	Teófilo Diaz Huamán DNI 42902939
Camion Volquete de 15m3 Marca Volvo NL12	Operativo	Gary Casas Quispe DNI 70054605
Camion Volquete de 15m³ Marca Volvo F12	Operativo	Amador Llanloy Paiona DNI 44535539
Camioneta marca Toyota Modelo Hilux 4x4	Operativo	Yoner Kisunco Llanloy DNI 71698637
Comprensora Neumatico Marca Sullair Modelo 375 con 2 Martillos	Operativo	
Comprensora Neumatico Marca Sullair Modelo 375 con 2 Martillos	Operativo	

Al respecto, se colige del acta de constatación suscrita, que su representada ha ***INCUMPLIDO CON LA PRESENCIA PERMANENTE DEL PERSONAL CLAVE Y DE LAS MAQUINARIAS OFERTADAS, conforme a lo contenido en los TDR, BASES INTEGRADAS, OFERTA GANADORA Y CONTRATO,***

Adicionado a ello, es menester precisar que a la actualidad y pese a habérsele emplazado en su oportunidad, el Consorcio Ayacucho, ***NO HA CUMPLIDO, con la ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD Y REQUERIMIENTO DE ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES EFECTUADAS AL PLAN DE TRABAJO, por parte del área usuaria.***

En tal sentido, á tenor de las consideraciones descritas en el párrafo precedente, el área usuaria y éste despacho, determinan que su representación legal, ***VIENE INCUMPLIENDO SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS EN LA CLAÚSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, TDR, BASES INTEGRADAS Y OFERTA GANADORA;***

En ese sentido, por la presente se le imputa el **INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES ESENCIALES**; por lo que en estricta observancia de lo previsto en el literal a) del numeral 164.1. del Artículo 164, concomitante con lo previsto en el numeral 165.1. del Art. 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el D.S. 344-2018-EF; ***SE LE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONFORME A LOS TDR APLICABLES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MATERIA DE CONTRATO, bajo APERCIBIMIENTO DE RESOLVER EL CONTRATO N°032-2022-GRA-PRIDER/DG***, para lo cual ***se le otorga un plazo de 03 días calendarios para revertir dicha imputación***, contabilizados a partir de la recepción de la presente misiva que se cursa por conducto notarial.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado
PRIDER
Ing. José Noé Cruz Díaz
DIRECTOR GENERAL

C.c.
INFRAESTRUCTURA- Seguimiento.
UAPF – Conocimiento e insertar en el expediente de contratación.
Archivo
JNCD/dpcm

Av. Evitamiento Nº 200- Jesús Nazareno- Ayacucho
Central Telefónica: (066) 780715
mesavirtual.prider@gmail.com
https://www.gob.pe/regionayacucho-prider

Fuente: Carta Notarial N° 060-2022-GRA-GG/PRIDER-DG, ofrecida como medio probatorio de la demanda, por el CONSORCIO.

64. De otra parte, de la revisión de la Carta Notarial N° 072-2022-GRA-GG/PRIDER-DG de fecha 14 de noviembre de 2022, la árbitra aprecia que el tenor de esta comunicación no comprende un nuevo apercibimiento de la Entidad, sino que dicha comunicación está orientada a dejar constancia que la persistencia de los incumplimientos imputados al Contratista mediante la Carta Notarial N° 060-2022-GRA-GG/PRIDER-DG y la aplicación de penalidades, transcurrido el plazo concedido, y en respuesta a los descargos presentados por el Contratista. Por lo que, dicha comunicación no requiere la verificación y cumplimiento de la formalidad establecida en el artículo 165 del RLCE, en la medida que no constituye un nuevo requerimiento formal enmarcado dentro del procedimiento de resolución contractual.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO - PRIDER

Exp 3137450

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Ayacucho, 09 de noviembre de 2022

CARTA NOTARIAL Nº 72 -2022-GRA-GG/PRIDER-DG

CARTA NOTARIAL Nº 3478 - 2022
JOSE HINOSTROZA AUCASIME
ABOGADO - NOTARIO PÚBLICO DE AYACUCHO
REG. C.A.A. Nº 096 - REG. C.N.A. Nº 01

Señor(a):
TEOFILO ABILIO GARCÍA DE LA CRUZ
Representante común del CONSORCIO AYACUCHO
Dirección: Urb. María Parado de Bellido Mz. "H" Lt. 01 - Carmen Alto - Ayacucho.
Ciudad. -

ASUNTO : COMUNICO DE FORMA REITERATIVA EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES – RESPUESTA A DESCARGO DE SU REPRESENTADA.

Ref. : a) Informe N°3892-2022-GRA-GG-PRIDER/DI-NOO
b) Informe N°568-2022-GRA-PRIDER-DI/RO-RUM
c) Informe N°3743-2022-GRA-GG-PRIDER/DI-NOO
d) Informe N°553-2022-GRA-PRIDER-DI/RO-RUM
e) Contrato N°032-2022-GRA-PRIDER/DG.

NOTARIA HINOSTROZA AUCASIME
14 NOV 2022
RECIBIDO
Hora: Firma:

Me dirijo a usted, a tenor de los documentos signados en el rubro referencial en el marco de la ejecución del Contrato N°032-2022-GRA-PRIDER/DG cuyo objeto es la Contratación del Servicio de Extracción, Apilamiento, Transporte, "Conformación de Enrocado y Filtros en cuerpo de presa, INCL. Excavación para el cimiento, para la Obra: Construcción del Sistema de Irrigación – Represa Pallcca en el Distrito de Quinua-Huamanga-Ayacucho"; cuyo plazo de ejecución es de 90 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y entrega de terreno.

Que, con Carta Notarial N°60-2022-GRA-GG/PRIDER-DG de fecha 12 de octubre de 2022, la Entidad le requirió el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de resolver el acotado documento contractual, en el marco de la imputación de la ausencia del personal clave ofertado, maquinaria ofertada, habiéndosele concedido un plazo de 03 días calendarios para revertir dicho hecho; que dentro del plazo concedido su representada no cumplió con lo requerido por la entidad, no revirtiendo tal imputación.

Que, mediante Carta N°021-2022-CONS-AYACUCHO/RC de fecha 19 de octubre de 2022, diligenciado por su representada, presenta la subsanación al incumplimiento de obligaciones contractuales (apercibimiento), misiva en la que expone una serie de supuestos que a criterio de su representada justifican la imputación comentada, las cuales calzan como afirmaciones subjetivas, toda vez que éstas no se sustentan en medios de prueba fidedignos, que reviertan dichos hechos, correspondiendo invalidarlos y no darlos como aceptados;

En tal orden de hechos, a posteriori, y habiendo precluido el plazo perentorio concedido, la Entidad, procedió a hacer la verificación in situ a través del Acta de Constatación de la Obra, advirtiendo la persistencia de los hechos imputados al jueves 20 de octubre de 2022: **LO QUE PERMITE A LA ACTUALIDAD RATIFICAR QUE SU REPRESENTADA INCURRE EN EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, INCURRIENDO EN PENALIDADES, DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA DEL CONTRATO.**

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado
PRIDER
Ing. José Noé Cruz Díaz
DIRECTOR GENERAL

C.c.
Archivo
JNCD/dpcm
Av. Evitamiento Nº 200- Jesús Nazareno- Ayacucho
Central Telefónica: (066) 780715
mesavirtual.prider@gmail.com
https://www.gob.pe/regionayacucho-prider

Indica que, habiendo precluido el plazo concedido, se procedió con la verificación in situ a través del Acta de Constatación de Obra, advirtiéndose que se incumplía sus obligaciones contractuales, incurriendo en penalidades.

Fuente: Carta Notarial N° 072-2022-GRA-GG/PRIDER-DG, ofrecida como medio probatorio de la demanda, por el CONSORCIO.

65. Aclarado dicho aspecto, se advierte que el PRIDER cumplió con el procedimiento previo de resolución requerido en el numeral 165.1 del artículo 165 del RLCE, puesto que a través de la Primera Carta Notarial efectuó el apercibimiento de las obligaciones contractuales, cumpliendo la formalidad establecida y otorgándole al CONSORCIO un plazo de subsanación no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

66. En tal sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del aspecto formal en el procedimiento de resolución, corresponde evaluar si la resolución contractual realizada por la Entidad se encuentra amparada en la causal de resolución de incumplimiento injustificado de obligaciones del Contratista contemplada en el

literal a) del numeral 164.1 del artículo 164 del RLCE, para ello el Tribunal Arbitral verificará si el incumplimiento imputado de obligaciones que motivó la resolución contractual era de carácter injustificado, pues solo cuando se cumpla dicha calificación (injustificado) nos encontraremos ante el supuesto habilitador de resolución contractual.

67. Según sostiene el CONSORCIO, dichos incumplimientos habrían sido subsanados oportunamente; no obstante, también señala que era justificada la ausencia del personal ofertado al 07 de diciembre de 2022 (fecha en que la Entidad realiza la constatación), pues no se tenía frente de trabajo, habiendo dicha parte procedido con la suspensión del servicio.

68. Sobre dicho extremo, la Árbitra Única estima pertinente señalar, que la resolución del contrato por incumplimiento requiere la verificación de la Entidad sobre del incumplimiento injustificado de obligaciones, una vez que haya vencido plazo otorgado para la subsanación conforme a lo dispuesto en el numeral 165.3 del artículo 165 del RLCE; pues no sería acorde al principio de buena fe y a los principios que inspiran el marco normativo, que una entidad procediera con la resolución contractual cuando a la fecha de la decisión de resolver el contrato la causal invocada hubiese desaparecido y/o hubiese sido subsanada.

69. La potestad de resolución contractual conlleva la verificación de un incumplimiento injustificado de las obligaciones del Contratista, que persista transcurrido el plazo otorgado en el requerimiento notarial de cumplimiento, de acuerdo con el criterio expuesto en la Opinión N° 083-2021/DTN con el cual la árbitra única comparte:

> OPINIÓN Nº 083-2021/DTN
>
> *2.1.2.(…)*
>
> *Como se aprecia del referido dispositivo, una de las causales de resolución contractual que prevé el Reglamento se configura cuando el contratista incumple injustificadamente sus obligaciones –contractuales, legales o reglamentarias- a pesar de haber sido requerido por la Entidad para revertir dicha situación de incumplimiento, lo cual implica que la continuación de ésta misma falta – injustificada- puede motivar la decisión de la Entidad de resolver el contrato.*
>
> *Adicionalmente, es importante acotar que el incumplimiento injustificado en la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista presupone la falta de sustento objetivo que, a juicio de la Entidad, no permite acreditar que dicho incumplimiento no le es atribuible al contratista; en ese contexto,* ***si pese al requerimiento previo, el contratista persistiera en incumplir las obligaciones pendientes de ejecución, injustificadamente, ésta situación configuraría la***

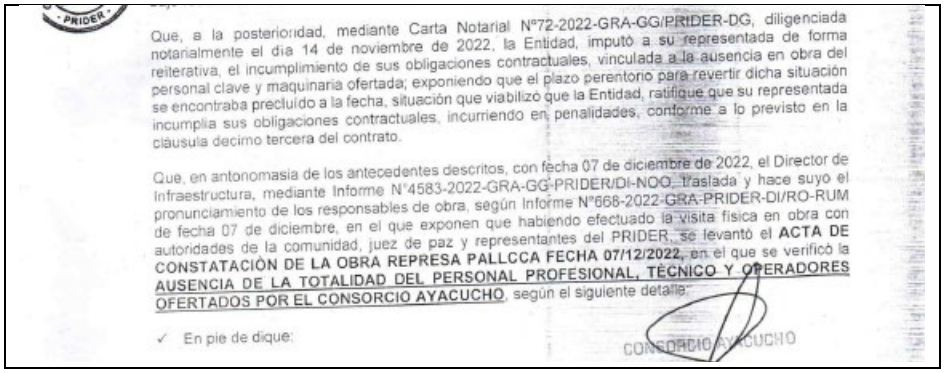
causal de resolución contractual prevista en el literal a) del numeral 164.1 del artículo 164 del Reglamento.

70. En ese sentido, si bien el CONSORCIO ha alegado haber subsanado los incumplimientos imputados, se debe indicar que no constituye materia controvertida la declaración de la subsanación o no subsanación efectuada por el CONSORCIO; correspondiendo que la Árbitra Única verifique para efectos del presente análisis, si la Entidad ha resuelto el contrato ante un supuesto de incumplimiento injustificado de las obligaciones por parte del CONSORCIO.

71. En relación a este aspecto, la árbitra no comparte el criterio señalado por el CONSORCIO respecto a la obligación de la Entidad de realizar un nuevo apercibimiento ante la existencia de un incumplimiento de obligaciones, pues precisamente el procedimiento de resolución del contrato aplicable comprende como garantía, una comprobación de que la situación de incumplimiento requerida persista o continúe, vencido el plazo otorgado en la comunicación de apercibimiento.

72. Por lo que, seguidamente, se procede a evaluar si el PRIDER en la Carta de Resolución motivó su decisión en el incumplimiento injustificado de las obligaciones del Contratista, vale decir, si para su decisión, consideró elementos que presuponían la evaluación del carácter injustificado de la obligación a cargo del CONSORCIO.

73. Del contenido de la Carta Resolutoria se aprecia que el PRIDER fundamentó su decisión de resolver el contrato en el incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales pese al haberse requerido para ello, indicando que el CONSORCIO continuaba incurriendo en el incumplimiento de sus obligaciones vinculadas a la ausencia del personal y maquinaria ofertada. Para dicho efecto, basó tal decisión en el Acta de constatación de obra de fecha 07 de diciembre de 2022, con la cual verificó la ausencia de la totalidad del personal profesional, técnico, y operadores ofertados, tal como se verifica a continuación:



Que, a la posterioridad, mediante Carta Notarial N°72-2022-GRA-GG/PRIDER-DG, diligenciada notarialmente el dia 14 de noviembre de 2022, la Entidad, imputó a su representada de forma reiterativa, el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, vinculada a la ausencia en obra del personal clave y maquinaria ofertada; exponiendo que el plazo perentorio para revertir dicha situación se encontraba precluido a la fecha, situación que viabilizó que la Entidad, ratifique que su representada incumplia sus obligaciones contractuales, incurriendo en penalidades, conforme a lo previsto en la clausula decimo tercera del contrato.

Que, en antonomasia de los antecedentes descritos, con fecha 07 de diciembre de 2022, el Director de Infraestructura, mediante Informe N°4583-2022-GRA-GG-PRIDER/DI-NOO, traslada y hace suyo el pronunciamiento de los responsables de obra, según Informe N°668-2022-GRA-PRIDER-DI/RO-RUM de fecha 07 de diciembre, en el que exponen que habiendo efectuado la visita fisica en obra con autoridades de la comunidad, juez de paz y representantes del PRIDER, se levantó el **ACTA DE CONSTATACIÓN DE LA OBRA REPRESA PALLCCA FECHA 07/12/2022**, en el que se verificó la **AUSENCIA DE LA TOTALIDAD DEL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OPERADORES OFERTADOS POR EL CONSORCIO AYACUCHO**, según el siguiente detalle:

✓ En pie de dique:

CONSORCIO AYACUCHO

Fuente: Carta Notarial N° 080-2022-GRA-GG/PRIDER-DG, ofrecida como medio probatorio de la demanda, por el CONSORCIO.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO - PRIDER

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

MAQUINARIA O PERSONAL TECNICO	MARCA/PLACA	SITUACION	OPERADOR
01 volquete	Volvo W3Q-864	inoperativa	sin operador
01 volquete	Volvo C9M-931	Inoperativa	sin operador
01 volquete	BAM-875	inoperativa	sin operador
01 excavadora	HYUNDAI 300LC-95	inoperativa	sin operador

✓ En botadero:

MAQUINARIA O PERSONAL TECNICO	MARCA/PLACA	SITUACION	OPERADOR
02 excavadoras	HYUNDAI 260 LC-95	Inoperativa	Sin operador

✓ En cantera:

MAQUINARIA O PERSONAL TECNICO	MARCA/PLACA
01 compresora	Atlas Copco XAS-185
01 compresora	Keaser M50
01 compresora	Sullair 375 CFM
01 camioneta	B6D-826
Yuver Llantoy Jayo	
Leder Urquizo Morera	

En tal sentido, conforme informa el área usuaria, su representada a la actualidad, CONTINUA INCURRIENDO EN EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES VINCULADAS A LA AUSENCIA DEL PERSONAL Y MAQUINARIA OFERTADA POR SU REPRESENTADA, lo que ha generado retrasos injustificados en la ejecución del proceso constructivo de obra; por lo que en estricta observancia de lo previsto en el literal a) y b) del numeral 164.1. del Artículo 164, concomitante con lo previsto en el numeral 165.1 y 165.5 del Art. 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el D.S. 344-2018-EF; ***SE LE COMUNICA LA RESOLUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO N°32-2022-GRA-PRIDER/DG POR LA CAUSAL DEL INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES PESE AL HABERSE REQUERIDO PARA ELLO,*** *de conformidad al acotado cuerpo normativo.* Los efectos jurídicos de la presente misiva notarial, surten desde el momento de su recepción.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL - AYACUCHO
Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado
PRIDER
Ing. Felix A. Huamani Mejia
DIRECTOR GENERAL (e)

C.c.
Archivo
FAHM/dpcm

Av. Evitamiento Nº 200- Jesús Nazareno- Ayacucho
Central Telefónica: (066) 780715
mesavirtual.prider@gmail.com
https://www.gob.pe/regionayacucho-prider

Señala que continúa el incumplimiento de sus obligaciones contractuales vinculadas a la ausencia de personal y maquinaria ofertada, por lo que se comunica la resolución parcial del contrato.

Fuente: Carta Notarial N° 080-2022-GRA-GG/PRIDER-DG, ofrecida como medio probatorio de la demanda, por el CONSORCIO.

74. A criterio de la Árbitra Única dicho fundamento de la Carta Resolutoria <u>no comprende una evaluación sobre el carácter injustificado de la obligación del CONSORCIO</u>, aspecto que, conforme se ha mencionado, constituye un requisito para que la Entidad proceda válidamente con la resolución contractual; por lo que la decisión adoptada se encontraría viciada.

75. En efecto, si bien el artículo 164.1 del artículo 164 del RLCE habilita la resolución del CONTRATO ante el incumplimiento del contratista, la constatación de la causal de resolución requiere la verificación de todos los elementos necesarios para su configuración, donde resulta esencial analizar el carácter injustificado del incumplimiento incurrido, así como las consideraciones de hecho y alegaciones que hayan planteadas por el contratista de forma previa a dicha decisión que permitan a la entidad concluir de forma objetiva la no existencia de una razón justificada.

76. Dicho análisis es inexistente en la Carta de Resolución del PRIDER, habiéndose hecho referencia a la existencia de un incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, sin considerar argumentos y/o elementos que objetivamente contribuyan a tal afirmación.

77. Es pertinente indicar, que el CONSORCIO ha resaltado la importancia que el cumplimiento de la motivación en el procedimiento de resolución contractual, indicando que el apercibimiento efectuado debe encontrase debidamente motivado conforme se reconoce en la Opinión N° 083-2021/DT, citada por dicha parte.

78. Igual criterio de "motivación" corresponde aplicarse en la Carta Resolutoria la misma que debe cumplir con una debida motivación para proceder con la resolución contractual, atendiendo a que el ejercicio de la función administrativa del Estado en el marco de la gestión de un contrato **requiere cumplir ciertos requisitos indispensables que los doten de validez**, tal como ha sido reconocido en la Opinión N° 111-2022/DTN con el cual esta árbitra comparte:

> *"Cabe precisar que la aplicación supletoria de las disposiciones compatibles del Código Civil a las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que regulan la ejecución contractual, no afecta ni excluye -cuando corresponda- la aplicación de las disposiciones de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General a las actuaciones que permiten a las Entidades manifestar su voluntad en el marco de una relación contractual bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado. Respecto de este último punto, cabe precisar que, si bien entre el contratista y la Entidad existe una relación de naturaleza contractual,* ***la formación de los actos a través de los cuales esta última manifiesta sus decisiones –durante la gestión de un contrato- deben cumplir ciertos requisitos indispensables que los doten de validez.*** *En ese sentido, dado que tales decisiones se generan en el desempeño de prerrogativas propias de la administración, corresponde aplicar aquellas disposiciones que regulan la función administrativa del Estado.*
>
> ***Así, por ejemplo, en el marco de una relación contractual –entre la Entidad y el contratista– las actuaciones que debe realizar la Entidad para expresar su voluntad (sea mediante decisiones o declaraciones) a efectos de que tengan validez deben*** *ser emitidos por el órgano facultado para ello -según su*

*competencia-, deben expresar su respectivo objeto (que deberá ajustarse al ordenamiento jurídico), **deben estar debidamente motivados**, deben perseguir las finalidades de interés público8 , entre otros aspectos, ello conforme al Principio de Legalidad9 .*

Ahora bien, lo anteriormente señalado no busca afirmar que las actuaciones que adopte la Entidad durante la ejecución contractual deben considerarse actos administrativos como tal –con todos los efectos que ello implicaría–, sino más bien, reconoce que tales actos y/o decisiones se generan en el ejercicio de la función administrativa, por lo que, de manera supletoria –es decir, en aquello no regulado en la normativa de contrataciones del Estado– pueden aplicarse las reglas propias de dicha función, contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, siempre que, previo análisis de compatibilidad, se determine, entre otros aspectos, que no contravienen disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado y/o no sean incompatibles con la naturaleza de aquella figura que se pretende aplicar.
(…)"

79. Dicho requisito de motivación comprende no solo el identificar las prestaciones u obligaciones que han sido incumplidas dentro del plazo otorgado, sino que también un razonamiento coherente y congruente sobre los hechos objetivos que conllevan a la entidad a adoptar tal decisión, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que justifican o sustentan el acto adoptado, en garantía del principio de legalidad, no cumpliéndose tal requisito cuando se aprecien fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación de la decisión[5].

80. En el caso en concreto, del contenido de la Carta Resolutoria no se aprecia una motivación coherente ni congruente que haya analizado la falta de sustento objetivo para acreditar que el incumplimiento de obligaciones no le es atribuible al CONSORCIO, lo que era de esperarse para que la Entidad adoptara tal decisión en forma concordante con el marco normativo.

81. Por lo tanto, considerando que no se cumplen los requisitos necesarios para la validez de la resolución contractual, corresponde declarar la invalidez e ineficacia de la resolución parcial del Contrato N° 032-2022-GRA-PRIDER/DG, efectuado por la Entidad

[5] De acuerdo con el numeral 6.1 del artículo 6 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado". Asimismo, se acuerdo con el numeral 6.3 del referido artículo: "No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto."

mediante Carta Notarial Nº 80-2022-GRA-GG/PRIDER-DG, de fecha 12 de diciembre de 2022.

82. Por tanto, corresponde declarar fundada la primera pretensión principal de la demanda interpuesta por el CONSORCIO.

b) Fundamentación de la Segunda Cuestión Controvertida

83. El punto controvertido que se procede a analizar es el siguiente:

> ii. **Segunda cuestión controvertida referida a la Segunda Pretensión Principal:**
> Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no ordenar al Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural de Ayacucho el pago pendiente a favor del Consorcio Ayacucho por la prestación efectivamente ejecutada a favor de la Entidad, por la suma de S/ 438,209.90 (Cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos nueve con 89/100 soles).

84. El CONSORCIO sustenta su pretensión en el incumplimiento del PRIDER de valorizar y pagar los servicios efectivamente ejecutados por el contratista con anterioridad a la resolución contractual.

85. Por su parte, el PRIDER ha señalado que dicha pretensión no puede ser materia de mayor pronunciamiento dado que en la demanda no existe medio probatorio alguno que sustente esta pretensión y sobre la cual podamos pronunciarnos.

86. El CONSORCIO señala que, desde el inicio de la prestación del servicio, ha cumplido con presentar las valorizaciones mensuales, de acuerdo a los metrados ejecutados en cada mes (agosto, setiembre, octubre y noviembre de 2022); sin embargo, el responsable del control de la ejecución del servicio (Supervisor de Obra), no cumplió con realizar los cálculos de los metrados correctamente, aprobando valorización por debajo de lo efectivamente realizado por el Consorcio.

87. Para sustentar su planteamiento sobre los metrados realmente ejecutados por el Consorcio y del saldo pendiente de pago, el CONSORCIO ofreció inicialmente como medio probatorio el informe técnico titulado "VALORIZACIÓN FINAL DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN, APILAMIENTO, TRANSPORTE, CONFORMACIÓN DE ENROCADO Y FILTRO DE CUERPO DE PRESA, INCL. EXCAVACIÓN PARA EL CIMIENTO, PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE IRRIGACIÓN - REPRESA PALLCCA EN EL DISTRITO DE QUINUA -HUAMANGA- AYACUCHO" (en adelante, el Informe Técnico)[6],

[6] Se precisa que mediante Resolución N° 07, la Árbitra Única concedió al CONSORCIO un plazo de cinco (5) días hábiles con el propósito de que precise si ofrecerá el Informe Técnico. Posteriormente, mediante Resolución N° 08, se otorgó un plazo adicional de diez (10) días hábiles, a fin de que EL

sin embargo, dicho informe no podrá ser objeto de valoración por parte de la Árbitra Única, siendo que, EL CONSORCIO no cumplió con presentarlo, pese a que recibió la información requerida al PRIDER. Al respecto, se debe precisar que, tal como fluye de lo expuesto por EL CONSORCIO en su escrito del 27 de junio de 2023 y tal como se dejó constancia en la Resolución N° 10, resulta claro que el Informe Técnico ofrecido por EL CONSORCIO no resultaba ser un documento existente y finalizado al momento de su ofrecimiento con la demanda, ya que, como es claro, este dependía de información que EL CONSORCIO, según lo afirmado, no tenía. Sin perjuicio de ello, en el proceso se entregó al CONSORCIO la información faltante; sin embargo, pese a ello, EL CONSORCIO no cumplió con presentar el Informe Técnico. En ese sentido, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley de Arbitraje, en atención a que es responsabilidad de las partes la presentación oportuna de los medios probatorios que sustentan sus pretensiones.

88. Sin perjuicio de los anterior, debe indicarse que, durante el trámite de las actuaciones arbitrales, el CONSORCIO presentó como nuevo medio probatorio el documento denominado INFORME DE VALORIZACIÓN MENSUAL DE OBRA N° 4 (CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022), mediante el cual detalla los trabajos efectivamente ejecutados por el demandante en el servicio; por lo que, dicho medio probatorio será considerado en el análisis del presente punto controvertido.

89. Ahora bien, respecto al punto controvertido materia de evaluación, la Árbitra Única advierte que el demandante pretende el reconocimiento de pago por el servicio efectuado por el CONSORCIO. Para dicha evaluación, resulta pertinente hacer referencia al marco legal y contractual aplicable al pago del SERVICIO.

90. En esa línea, la Cláusula Cuarta del Contrato estableció que el pago de la contraprestación al Contratista se realizará en pagos parciales de manera mensual, **previa sustentación con documentos que acrediten dicha valorización mensual, previa conformidad del Residente de Obra y visto bueno de la Supervisión de Obra,** tal como se aprecia a continuación:

CONSORCIO cumpla con remitir el Informe Técnico ofrecido como medio probatorio. No obstante, pese a ello, EL CONSORCIO no cumplió con remitir el Informe Técnico ofrecido, por lo que, mediante Resolución N° 09, se dejó constancia de tal situación y se decidió prescindir de dicho medio probatorio. Ahora bien, resulta importante precisar que dicha Resolución, en el extremo comentado, fue objeto de reconsideración por parte del CONSORCIO, siendo que, mediante Resolución N° 10, tal recurso fue acogido por la Árbitra Única y, por tanto, se requirió al PRIDER para que cumpla con presentar los resultados obtenidos en la constatación del día 20 de junio de 2023, respecto al avance ejecutado por el CONSORCIO. Ello permitiría al CONSORCIO presentar el Informe Técnico. Ahora bien, resulta importante señalar que, tal como consta en la Resolución N° 14, una vez que el PRIDER presentó lo requerido, esto le fue trasladado al CONSORCIO. Finalmente, pese a lo señalado, el CONSORCIO no cumplió con presentar el Informe Técnico comprometido y, mediante Resolución N° 17, se declaró el cierre de las actuaciones arbitrales.

(Ver página siguiente)

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en pagos parciales de manera mensual, previa sustentación con documentos que acreditan dicha valorización mensual, previa conformidad Residente de Obra y visto bueno de la Supervisión de Obra.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

91. De lo expuesto, se desprende que para los pagos parciales se requería previamente lo siguiente:

(i) La presentación del Contratista de la sustentación con documentos que acrediten dicha valorización, es decir las prestaciones realizadas durante el mes de valorización; y

(ii) La conformidad de la prestación previa del Residente de Obra y visto bueno de la Supervisión de obra.

92. Tales condiciones del pago del servicio fueron recogidas de las Bases Integradas del Servicio, que forman parte integrante del Contrato, en las cuales a través de los numerales 7.7 y 7.8, se estableció que la forma de pago será en pagos parciales o periódicos, previa sustentación documentada de la valorización mensual y previa presentación de la conformidad de la prestación a cargo del Residente de Obra y visto bueno de la Supervisión de obra, decretado por la Dirección de Infraestructura:

7.7 Conformidad de la Prestación

Será otorgado por el Residente de Obra y V°B° del Supervisor de Obra, decretado por la Dirección de Infraestructura y conforme lo dispone el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.8 Forma de Pago

La forma de pago será en PAGO PARCIALES O PERIODICOS, previa sustentación con documentos que acrediten dicha valorización mensual, previa presentación de documentos exigidos en el numeral 7.7 del presente.

93. Por otro lado, la Cláusula Cuarta del Contrato también reconoce un plazo máximo de siete días, para que el responsable de otorgar la conformidad lo efectúe, reconociendo que cuando se requieran efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, tal conformidad deberá emitirse en un plazo máximo de quince días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

94. En el presente caso, el CONSORCIO señala que ha cumplido con presentar las valorizaciones mensuales, de acuerdo con los metrados ejecutados en cada mes (agosto, setiembre, octubre y noviembre de 2022); sin embargo, el demandante alega que el responsable del control de la ejecución del servicio (Supervisor de Obra), no cumplió con realizar los cálculos de los metrados correctamente, aprobando la valorización por debajo de lo efectivamente realizado por el Consorcio.

95. Respecto a la medición y forma de pago, es preciso indicar que el Servicio consideró que el volumen a reconocerse por trabajo ejecutado será equivalente al número de metros cúbicos (m3) de material colocado en el lugar respectivo, es decir, la valorización se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el precio unitario de la partida material seleccionado, tal conforme se muestra a continuación:

> *"El volumen y a reconocerse como trabajo ejecutado, será el número de metros cúbicos (m3) de material colocado en el lugar respectivo, de acuerdo a la dosificación aprobada por el Supervisor de Obra.*
>
> *La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el precio unitario de la partida material seleccionado, el cual constituye compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc, y otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra"*

96. Sin embargo, de los actuados, la Árbitra Única no aprecia elementos objetivos que evidencien que el CONSORCIO haya valorizado oportunamente las prestaciones cuyo pago es reclamado y que estos trabajos cuenten con la conformidad correspondiente, de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato para la procedencia del pago.

97. Es así que, de los actuados no se encuentra acreditado ni sustentado que, en las valorizaciones de agosto, setiembre, octubre y noviembre de 2022 presentadas oportunamente a la Entidad durante la ejecución del contrato, el CONSORCIO haya valorizado la suma no reconocida de S/ 438.209.90 (Cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos nueve con 90/100 soles), ni que la Entidad no haya aprobado injustificadamente dichos trabajos, como alega el CONSORCIO.

98. Es preciso indicar que las valorizaciones del servicio requieren de la conformidad de la prestación previa por parte del Residente de Obra y visto bueno de la Supervisión de obra, conforme lo dispone el artículo 168 del RLCE. No obstante, ello no sucedió ni, tampoco, existe medio probatorio sucedáneo que -de forma razonable- permita, a la Árbitra Única, inferir que las valorizaciones presentadas hayan sido pagadas por montos inferiores a los realmente ejecutados por EL CONSORCIO.

99. En esa línea, debe tenerse presente que de acuerdo con el artículo 171 del RLCE, en

mención, la obligación de pago de las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista se genera una vez emitida la conformidad correspondiente de los bienes, servicios en general y consultorías, **siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato**, tal como se cita a continuación:

> *Artículo 171. Del pago*
> *171.1. La* ***Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.***
> *171.2. En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.*
> *171.3. Las controversias en relación a los pagos a cuenta o pago final pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje.*
> *171.4. De conformidad con lo establecido en el numeral 39.1 del artículo 39 de la Ley, excepcionalmente el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando este sea condición de mercado para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, previo otorgamiento de la correspondiente garantía por el mismo monto del pago.*
> *171.5. Conforme a lo establecido en el numeral 45.36 del artículo 45 de la Ley, el pago reconocido al proveedor o contratista como resultado de un proceso arbitral se realiza en la oportunidad que establezca el respectivo laudo y como máximo junto con la liquidación o conclusión del contrato, salvo que el proceso arbitral concluya con posterioridad.*

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

100. De lo expuesto, se determina que el pago de servicio solo procede después de ejecutada la respectiva prestación y otorgada su conformidad a cargo del responsable, cuando éste se ha cumplido todas las características y condiciones contractuales del contrato y documentos que lo conforman, actividad que se encuentra bajo responsabilidad de la Entidad.

101. Por lo que, no encontrándose acreditado de los actuados el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato para el pago del monto reclamado por el CONSORCIO, no corresponde que se reconozca suma pendiente de pago a su favor.

102. Adicionalmente, debemos considerar que, bajo dicho marco legal y contractual, no es contradictorio entre las Partes que el PRIDER aprobó oportunamente las valorizaciones y pagos parciales por los servicios prestados en agosto, setiembre, octubre y noviembre, los cuales tienen carácter final y definitivo, no apreciándose que el CONSORCIO haya cuestionado en arbitraje tales pagos efectuados, que se

detallan a continuación[7]:

Mes	Monto aprobado por el PRIDER
Agosto	S/ 203,014.92
Setiembre	S/ 324,267.67
Octubre	S/ 328,524.75
Noviembre	S/ 288,385.32
Total	S/ 1,144,192.66

Fuente: Escrito de demanda, presentado por el CONSORCIO.

103. Específicamente, sobre el medio probatorio denominado INFORME DE VALORIZACIÓN MENSUAL DE OBRA N° 4 (CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022), que detallaría los trabajos efectivamente ejecutados por el demandante hasta la fecha de la resolución del contrato, la árbitra estima pertinente indicar que dicho medio probatorio resulta insuficiente para sustentar el pago que es reclamado por el CONSORCIO, pues no se ha logrado generar certeza sobre el contenido de dicho documento corresponde a la valorización correspondiente del año 2022, presentada durante la ejecución del contrato, y que la Entidad haya emitido su conformidad respectiva y/o aprobado la misma. Por el contrario, ha sido contradicho por el PRIDER, en informe adjunto al escrito de fecha 19 de octubre de 2023, que dicha Valorización mensual de Obra N° 04 corresponda a la presentada durante la ejecución contractual, sino que en realidad correspondería a una presentada con carta de fecha 24 de agosto de 2023, es decir, posterior a la resolución del contrato, tal como se aprecia a continuación:

II. ANALISIS

De los antecedentes recabados de la Entidad, se tiene que:

- Con fecha 30 de noviembre 2022 el Contratista, presentó por mesa de partes de la Entidad su carta No 026-2022-CONS-AYACUCHO/RC con asunto "REMITO VALORIZACION N° 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022" en 061 folios por un monto a valorizar de S/.591,299.81. En dicho expediente se cuenta con planilla de valorización, planilla de metrados y planos suscritos por el Jefe de Brigada Ing. Amador Delfín Ramírez Cárdenas

- Con fecha 24 de agosto 2023 el Contratista, presentó por mesa de partes de la Entidad su carta No 002-2023-CONS-AYACUCHO/RC con asunto "REMITO VALORIZACION N° 04", en cuyo cuerpo de carta señala que corresponde al mes de noviembre 2022; en 49 folios. Por un monto a valorizar de S/.577,005.87. En dicho expediente se cuenta con planilla de valorización, planilla de metrados y planos suscritos por el Jefe de Brigada Ing. Amador Delfín Ramírez Cárdenas

[7] Al respecto, debemos señalar que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1229° del Código Civil que dispone que la prueba del pago le corresponde a quien pretende haberlo realizado, ambas partes reconocen que el pago realizado por el PRIDER se realizó y asciende a S/ 1,144,192.66 (un millón ciento cuarenta y cuatro mil ciento noventa y dos y 66/100 soles). Lo anterior, lo podemos ubicar, por ejemplo, en el cuadro elaborado por EL CONSORCIO y que figura en la página 18 de su demanda.

Visto ambos expedientes de valorización podemos advertir lo siguiente:

- Haciendo un comparativo entre las secciones transversales de los planos adjuntos a sus valorizaciones, podemos advertir que el trazo de corte o excavación es muy distinto.

  En los planos adjuntados en su carta del 30 de noviembre 2022, el Jefe de Brigada deja constancia que la excavación la hizo a una profundidad determinada y con el mismo talud del cuerpo de dique

  Sin embargo, en los planos adjuntados en su carta 24 de agosto 2023, el Jefe de Brigada señala que la excavación fue realizada a mayor profundidad y con un talud distinto al cuerpo de dique (más vertical)

- Haciendo un comparativo entre las secciones transversales de los planos adjuntos a sus valorizaciones, podemos advertir que las secciones de las capas de filtros (M6 y M7) y enrocados (M8 y M9) son muy distintos en áreas, cotas superficial y cota de base.

- De la carta del 24 de agosto 2023, podemos advertir que existe discrepancia entre las áreas que figuran en los planos y las áreas de las planillas de metrados; por lo que no es fiable la información contenida en dichos documentos.

  - La variación en las cotas de corte (Profundidad y talud) implica la variación en la planilla de metrados de excavación y conformación de filtros y enrocados y consecuentemente genera una variación en el monto a valorizar.

Con ello se desprende que ambas valorizaciones (inc. Planos) son totalmente contradictorios entre sí; es decir, el Contratista ha variado arbitraria e intencionalmente los datos proporcionados por el mismo. Lo cual, deviene en una nula fiabilidad de dichos documentos presentados por el Contratista.

Por otra parte, informamos que se ha realizado un comparativo entre las secciones de los planos constatados VS los planos presentado por el Contratista en Carta No 002-2023-CONS-AYACUCHO/RC vs Carta No 026-2022-CONS-AYACUCHO/RC. De lo cual se puede advertir que no se tiene concordancia entre ningún plano, tanto en cotas superficiales como cotas inferiores (base), lo que generaría diferencia de metrados. Se adjuntan los cuadros comparativos por progresivas.

III. RECOMENDACIONES

En vista de que existe contradicción entre los documentos presentados por propio Consorcio Ayacucho (Carta No 002-2023-CONS-AYACUCHO/RC vs Carta No 026-2022-CONS-AYACUCHO/RC.), se infiere que éste no se cuenta con información fiable.

Considerando que existe una valorización autorizada, aprobada y pagada por los Ex responsables de obra del periodo 2022 y en vista de que es el Contratista quien está controvirtiendo los montos valorizados, y con ello las cantidades valorizadas es que se recomienda realizar una constatación notarial con la apertura de zanjas para verificar las cotas de base (Cimentación) considerando que es el principal punto de controversia. Lo cual deberá ser pagada por el Contratista.

Se adjunta:

- Cuadro comparativo.
- Acta de Constatación Notarial del 20 de junio 2023.
- Carta No 026-2022-CONS-AYACUCHO/RC

Es todo cuanto informo a usted para conocimiento y fines pertinentes.

104. Por lo que, considerando que el PRIDER ha negado haber aprobado dicha valorización actualiza presentada en agosto de 2023, no resulta posible concluir, como pretende EL CONSORCIO, que existan valorizaciones aprobadas que se encuentren pendientes de pago por parte del PRIDER que sean exigibles y que correspondan ser reconocidas por la real ejecución de los servicios del CONSORCIO.

105. Al respecto, debe tenerse presente que la carga de la prueba corresponde a quien alega determinado hecho, tal como -por ejemplo- el hecho de que se hayan realizado pagos por montos menores a los que debió haber correspondido al CONSORCIO por concepto de la ejecución sus servicios. En ese sentido, respecto del presente punto, resulta necesario recordar lo que, para nuestro ordenamiento, significa la carga de la prueba. En ese sentido, el artículo 196 del Código Procesal Civil dispone lo siguiente:

> **Carga de la prueba. -**
> Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, **la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión**, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

106. En el presente caso, EL CONSORCIO no ha podido acreditar que existan trabajos que hayan sido objeto de valorización y aprobación oportuna por parte del PRIDER, por consiguiente, que exista un pago adeudado pendiente, de acuerdo con el procedimiento de pago contemplado en el Contrato.

107. Por lo explicado, corresponde declarar infundada la segunda pretensión principal de la demanda interpuesta por el CONSORCIO.

c) Fundamentación de la Tercera Cuestión Controvertida

108. El punto controvertido que se procede a analizar es el siguiente:

iii.	**Tercera cuestión controvertida referida a la Pretensión Subordinada a la Segunda Pretensión Principal:** De no admitirse la Segunda Pretensión Principal, que el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no ordenar al Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural de Ayacucho el pago de la suma de S/ 438,209.90 (Cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos nueve con 90/100 soles), como reparación por el daño emergente ocasionado al Consorcio Ayacucho.

109. Habiéndose determinado que no corresponde amparar la Segunda pretensión principal de la demanda, corresponde analizar la pretensión subordinada a esta, considerando que según la doctrina nacional, la pretensión subordinada se presenta "cuando el demandante formula en primer término una pretensión y en caso de que esta no sea acogida, subsidiariamente hace otra petición (…) solo cuando (la

pretensión principal) no sea acogida, entrará en el examen la subordinada para ver si merece reconocerse".[8]

110. Respecto del presente punto, EL CONSORCIO sustenta su pretensión en los mismos fundamentos de hecho que los analizados en el punto controvertido previo.

111. Del mismo modo, el PRIDER se pronuncia de la misma manera y afirma que en la demanda no existe medio probatorio alguno que sustente su pretensión y sobre la que puedan pronunciarse.

112. Ahora bien, respecto de los fundamentos de derecho esgrimidos por EL CONSORCIO, este subdivide los elementos de la responsabilidad civil y los justifica, principalmente, de la siguiente manera:

a. Sobre la antijuridicidad:

Afirma que EL CONSORCIO se vio obligado a suspender las labores en campo, toda vez que les fue imposible ejecutar el servicio de "Conformación y enrocado de protección, relleno tipo M8", ya que el PRIDER no cumplió con su obligación de suministrar el referido material de relleno tipo M8, máxime cuando EL CONSORCIO, en su oferta o desagregado de costos unitarios, nunca consideró el suministro de dicho material.

Por ello, pese a los requerimientos que EL CONSORCIO realizó, el PRIDER no cumplió con su obligación de suministrar el material tipo M8, razón por la que EL CONSORCIO tuvo que resolver el contrato por la causal "incumplimiento de obligación esencial del PRIDER.

b. Sobre el Factor de Atribución:

EL CONSORCIO imputa al PRIDER haber incurrido en culpa inexcusable, regulado por el artículo 1319 del Código Civil, debido a la falta de diligencia de este último en el cumplimiento de sus obligaciones. En ese sentido, EL CONSORCIO resalta que la obligación del PRIDER consistente en suministrar el material de tipo M8 resultaba esencial para que EL CONSORCIO pueda realizar el servicio de "Conformación y enrocado de protección, relleno tipo M8".

c. Sobre la determinación de daños:

EL CONSORCIO afirma que el daño emergente se presenta en la diferencia comprobada entre el pago por los metrados realmente ejecutados y el pago

[8] Sotero, M. (2013). La acumulación de pretensiones a la luz de la Tutela Jurisdiccional efectiva Análisis de las reglas del Código Procesal Civil conforme a la Constitución de 1993. Derecho & Sociedad 40 (pp. 181 – 194).

realizado por el PRIDER. En ese sentido, mientras el PRIDER pagó S/ 1,144,192.66 (un millón ciento cuarenta y cuatro mil ciento noventa y dos y 66/100 soles)[9], lo cierto es que debió haber pagado S/ 1,582,402.90 (un millón quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos dos y 90/100 soles), por lo que el perjuicio asciende a S/ 438.209.90 (cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos nueve y 90/100 soles).

d. Sobre el nexo causal:

Según EL CONSORCIO, el nexo de causalidad entre el hecho y el daño producido se representa por el incumplimiento, por parte del PRIDER, de su obligación esencial consistente en suministrar el material de tipo M8.

113. Al respecto, la Árbitra Única considera que resulta importante recordar que, la doctrina reconoce cuatro elementos conformantes de la responsabilidad civil:

- **La antijuridicidad**; entendida como la conducta contraria a ley o al ordenamiento jurídico;
- **El factor de atribución**; que es el título por el cual se asume responsabilidad, pudiendo ser este subjetivo (por dolo o culpa) u objetivo (por realizar actividades o, ser titular de determinadas situaciones jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico), considerándose inclusive dentro de esta subclasificación al abuso del derecho y la equidad (Cfr. ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de la Responsabilidad Civil. Primera Edición, Gaceta Jurídica Sociedad Anónima, Lima, 2002; página 80);
- **El nexo causal o relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido**; y
- **El daño,** que es consecuencia de la lesión al interés protegido y puede ser patrimonial (daño emergente o lucro cesante) o extrapatrimonial (daño moral y daño a la persona).

114. En el presente caso, la Árbitra Única debe recordar que los elementos enumerados previamente deben configurarse de forma conjunta. En ese sentido, si es que uno de ellos no se encuentra presente, no será posible determinar la existencia de responsabilidad civil alguna.

[9] Se deja constancia de que en el fundamento jurídico N° 14 de la pretensión bajo análisis EL CONSORCIO afirma que lo pagado asciende a S/ 1,444,192.66 (un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y dos y 66/100 soles). No obstante, de la lectura de la demanda en su integridad se aprecia que ello corresponde a un error tipográfico originado en el fundamento jurídico N° 10 del sustento de la Segunda Pretensión Principal, puesto que el cuadro presentado afirma que lo pagado por el PRIDER asciende a S/ 1,144,192.66 (un millón ciento cuarenta y cuatro mil ciento noventa y dos y 66/100 soles), lo que coincide con las operaciones aritméticas realizadas para justificar el monto reclamado por EL CONSORCIO, siendo que por error, en dicho párrafo (por primera vez) se comete el señalado error tipográfico y se confunde la cifra citada y se coloca -por error- el monto de S/ 1,444,192.66 (un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y dos y 66/100 soles).

115. En el presente caso, resulta de especial importancia el cálculo del daño reclamado por EL CONSORCIO, razón por la que el análisis comenzará en dicha etapa. Así pues, debemos recordar que el análisis requerirá que todos y cada uno de los elementos se configure, a fin de determinar cualquier tipo de responsabilidad civil. En ese sentido, OSTERLING PARODI[10] afirma lo siguiente:

> *"Para que haya un daño contractual resarcible no basta que se incumpla la obligación y que el incumplimiento sea imputable al deudor. Es necesario, además, que el incumplimiento produzca un perjuicio. Toda reclamación de daños y perjuicios, aunque se funde en un derecho inobjetable a exigirlos, requiere la prueba de su existencia. Para declarar la responsabilidad no basta comprobar judicialmente la infracción de la obligación; es preciso demostrar la existencia de los daños y perjuicios.*
> *A este respecto, establece el artículo 1331 del Código Civil que "la prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso".*
> *Por ello, el incumplimiento de un contrato no origina necesariamente el derecho a una indemnización. Tiene que haber un daño. La responsabilidad civil, a diferencia de la responsabilidad penal, no es punitiva."*

116. Como vemos, resulta clara la necesidad de que se presenten todos los elementos de la responsabilidad civil. Entre ellos, uno de los principales, resulta ser que exista un perjuicio. No puede existir una demanda que pretenda una indemnización si es que esta no encuentra su origen en un perjuicio que busca ser resarcido.

117. En el presente caso, a fin de analizar si es que se configuró, o no, la antijuridicidad en el presente caso resulta importante recordar que esta se configurará cuando determinada conducta sea contraria a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico. En ese sentido, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República ha tenido la oportunidad de pronunciarse manifestando lo siguiente:

> *"Décimo Cuarto.- La ilicitud de una conducta en el ámbito de la responsabilidad civil debe ser concebida como aquel* ***hecho jurídico voluntario contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres****."*
>
> [Casación N° 2360-2017-LIMA]

118. En el mismo sentido, el profesor ESPINOZA ESPINOZA señala:

> *"Entre nosotros, se afirma que una conducta es antijurídica 'no solo cuando contraviene una norma prohibitiva, sino también cuando la conducta viola el*

[10] OSTERLING, Felipe (1968). La Indemnización de Daños y Perjuicios. En: https://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/La%20indemnizacion%20de%20da%A4os.pdf. P. 5

sistema jurídico en su totalidad, en el sentido de afectar los valores o principios sobre los cuales ha sido construido el sistema jurídico'. Por ello, en materia de conductas humanas que puedan causar daños, se debe distinguir la atipicidad de las mismas en materia extracontractual, de la tipicidad en materia contractual"

119. En concreto, el Código Civil dispone lo siguiente sobre el presente punto:

> *Indemnización por dolo, culpa leve e inexcusable*
> *Artículo 1321.-* ***Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve.***
> *El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución.*
> *Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída.*

120. Como vemos, en casos de responsabilidad contractual, la antijuridicidad viene determinada por el incumplimiento de la obligación comprometida. Así pues, vemos que es unánime, en tanto la Corte Suprema y la Doctrina se encuentran de acuerdo, que la antijuridicidad de una conducta se determina con la verificación de que dicha conducta represente una vulneración del ordenamiento nacional. Ello, para el caso de la responsabilidad contractual, se materializa con la ejecución defectuosa o, en todo caso, de la inejecución de la obligación asumida.

121. En el presente caso, el CONSORIO sustenta la antijuricidad en el incumplimiento del PRIDER de proporcionar el material relleno tipo M8, calificando dicha obligación como "esencial", en tanto era indispensable para proseguir con la prestación del servicio.

122. Al respecto, la Árbitra Única advierte que existe una diferencia entre las partes respecto al alcance de las obligaciones comprendidas en el contrato. Mientras que para el CONSORCIO dicho aspecto le correspondía a la Entidad como una obligación esencial, para el PRIDER este aspecto debía ser cumplido por el Contratista.

123. Sobre el particular, resulta importante considerar que los contratos celebrados bajo el régimen de la contratación pública son resultado de un procedimiento de contratación caracterizado por una serie de actuaciones y requisitos formales, que garantizan su validez y el resultado de los futuros términos contractuales.

124. Bajo dicho marco, y luego de cumplidas las etapas correspondientes del procedimiento de contratación, las partes celebran el contrato, el cual comprende el acuerdo de ambas para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica

dentro de los alcances de la Ley y el Reglamento[11], **sobre la base de las condiciones establecidas en los documentos del procedimiento de selección y la oferta ganadora**[12].

125. Por regla general, los contratos regidos por la normativa de contratación pública se perfeccionan con la suscripción del documento que lo contiene; adicionalmente, cabe **indicar el contrato está conformado además del documento que lo contiene, por los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes**. De esta manera, el documento que contiene el contrato debe comprender las reglas definitivas de los documentos del procedimiento de selección que han establecido las obligaciones y condiciones que regirán el futuro contrato, siendo el contrato obligatorio para las partes una vez que ha sido perfeccionado, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la LCE[13] y los artículos 137 y 138 del RLCE[14].

126. Es preciso indicar que según la posición del CONSORCIO, al momento de suscribirse el contrato, la Entidad modificó el ítem: "conformado de enrocado de protección, relleno tipo M8", por "suministro y conformación de enrocado de protección, relleno

[11] De acuerdo con la definición de "Contrato" prevista en el Anexo de Definiciones del RLCE.
[12] De acuerdo con la definición de "Contrato original" prevista en el Anexo de Definiciones del RLCE.
[13] *Artículo 32. el contrato*
32.1 El contrato debe celebrarse por escrito y se ajusta a la proforma incluida en los documentos del procedimiento de selección con las modificaciones aprobadas por la Entidad durante el mismo.
(…)
32.4 El reglamento establece el procedimiento, plazos y requisitos para el perfeccionamiento del contrato, así como los casos en que el contrato puede perfeccionarse mediante una orden de compra o servicio, no debiendo necesariamente en estos casos incorporarse las cláusulas indicadas, sin perjuicio de su aplicación legal.
(…)
[14] *Artículo 137. Perfeccionamiento del contrato*
137.1. El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos derivados de procedimientos de Subasta Inversa Electrónica y Adjudicación Simplificada para bienes y servicios en general, en los que el contrato se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicios, conforme a lo previsto en los documentos del procedimiento de selección, siempre que el monto del valor estimado no supere los Cien Mil con 00/100 Soles (S/ 100 000,00).
(…)
Artículo 138. Contenido del Contrato
*138.1. El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que **establezcan obligaciones para las partes**.*
(…)
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas cláusulas, durante la ejecución contractual, da el derecho a la Entidad correspondiente a resolver automáticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

tipo M8"; no obstante el suministro no estaba considerado en los términos de referencia de las bases integradas del procedimiento de selección Concurso Público N° 02- 2022-GRA-PRIDER/CS-1 ni el desagregado de partidas que sustenta su oferta presentada; por lo que dicha incorporación debe considerarse inexistencia de acuerdo con la Opinión N° 10-2019/DTN de la Dirección Técnica de Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.

127. Que, revisados los alcances de la contratación contenidos en las Bases Integradas que dieron origen al contrato, se advierte que, en efecto, el suministro del material relleno tipo M8 no estaba considerado en el alcance del servicio, sino únicamente la conformación de enrocado de protección del relleno tipo M8:

5.1 Descripción y Cantidad del Servicio a Contratar

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
01	Servicio de EXTRACCION, APILAMIENTO, TRANSPORTE, CONFORMACION DE ENROCADO Y FILTROS EN CUERPO DE PRESA – A TODO COSTO	Servicio	01
	Para el presente servicio deberá realizar entre otros, los siguientes trabajos:		
	Extracción y apilamiento de material para enrocado	M3	56,537.44
	Carguío y transporte de material para enrocado de cantera a obra, dist. prom 3.0 km	M3	76,325.54
	Conformación de enrocado de protección, relleno tipo m8	M3	12,781.53
	Conformación y compactación controlado del terraplén con material de préstamo	M3	7,513.70
	Conformación de enrocado aguas abajo de dique, diámetro >10"	M3	47,069.64
	Cobertura con enrocado de terraplén expuesto aguas abajo, diámetro<5", e:0.50m	M2	208.78
	Suministro e instalación de filtro de piedras filtro 1	M3	3,838.80
	Suministro e instalación de filtro de piedras filtro 2	M3	3,784.95
	Excavación masiva en material compacto en pie de dique aguas abajo	M3	17,660.51
	Excavación en roca fija con voladura controlada para perfilado	M3	11,773.67
	Perfilado manual de talud aguas abajo	M2	2,847.06

128. Sin embargo, se constata que dicho aspecto habría sido incorporado por el PRIDER a la suscripción del contrato en la cláusula tercera, a través de la cual se habría alternado las condiciones de las contratación contenidas en las Bases Integrados, que determinaron las reglas definitivas del contrato:

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 3 706 125.19 (Tres millones setecientos seis mil ciento veinticinco con 19/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ITEM	DESCRIPCION	Und.	Metrado	P. Unitario	Precio
1	EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL PARA ENROCADO	M3	56.537.44	18.44	1.042.550.394
	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ENROCADO DE CANTERA A OBRA, DIST. PROM 3.0 KM	M3	76.325.54	4.76	363.309.570
	SUMINISTRO Y CONFORMACIÓN DE ENROCADO DE PROTECCIÓN, RELLENO TIPO M8	M3	12.781.53	15.03	192.106.396
	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CONTROLADO DEL TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	M3	7.513.70	6.58	49.440.146
	CONFORMACIÓN DE ENROCADO AGUAS ABAJO DE DIQUE, DIÁMETRO >10"	M3	47.069.64	5.03	236.760.289
	COBERTURA CON ENROCADO DE TERRAPLÉN EXPUESTO AGUAS ABAJO, DIÁMETRO<5", E:0.50M	M2	208.78	5.15	1.076.219
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE PIEDRAS FILTRO 1	M3	3.838.80	162.86	625.186.968
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE PIEDRAS FILTRO 2	M3	3.784.95	163.34	618.233.733
	EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL COMPACTO EN PIE DE DIQUE AGUAS ABAJO	M3	17.660.61	10.86	191,794.225
	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CON VOLADURA CONTROLADA PARA PERFILADO	M3	11.773.67	32.07	377.581.597
	PERFILADO MANUAL DE TALUD AGUAS ABAJO	M2	2.847.06	2.84	8.085.650
	TOTAL S/				3,706,125.19

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

Fuente: Cláusula tercera del contrato.

129. En tal sentido, la Árbitra Única considera atendible lo señalado por el CONSORCIO sobre el criterio indicado en la Opinión N° 10-2019/DTN, respecto a que dicha inclusión que incorpora una modificación a las reglas definitivas de la contratación contenidas en las Bases Integradas, se considera inexistente e incapaz de desplegar efectos jurídicos en la medida que se ha probado que dicha inclusión referida del contrato no respondía a las condiciones finales de la contratación y que el CONSORCIO nunca manifestó su voluntad de someterse a dicha estipulación, de acuerdo a los artículos 168°, 1361° y 1362° del Código Civil.[15]

[15] *Obligatoriedad de los contratos*
Artículo 1361°.- ***Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos.***
Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla.
Interpretación objetiva
Artículo 168°.- ***El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe.***
Buena Fe Artículo 1362°.-

130. En tal sentido, siendo que los contratos deben ser interpretados según las reglas de la buena fe y común intención de las partes, se considera inexistente e incapaz de desplegar efectos jurídicos la referencia al suministro del material relleno tipo M8 estipulado en el Contrato.

131. Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo a que el suministro del material relleno tipo 8 no se encuentra dentro de los alcances del contrato, dicho aspecto no puede ser determinado como una obligación esencial del contrato conforme al criterio de la Opinión N° 027-2014/DTN, ni, por ende, podemos hacer referencia a un incumplimiento.

132. La Árbitra Única considera pertinente resaltar que, en la opinión señalada, el OSCE refiere con claridad que una obligación esencial es aquella cuyo cumplimiento resulta indispensable para alcanzar la finalidad del contrato y, en esa medida, satisfacer el interés de la contraparte; estableciéndose como condición adicional para tal calificación que se haya contemplado en las Bases o en el contrato:

> Opinión N° 027-2014/DTN:
> *"Como se aprecia, un contrato suscrito bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado puede resolverse por el incumplimiento de las obligaciones del contratista o por el incumplimiento de las* ***obligaciones esenciales*** *de la Entidad. En este último caso, el contratista puede resolver el contrato cuando el incumplimiento de la Entidad implique la inobservancia de alguna de sus obligaciones esenciales, las mismas que deben estar contenidas en las Bases o en el contrato.*
> *(…)*
> *2.3. De conformidad con lo expuesto, se puede inferir que una obligación esencial es aquella cuyo cumplimiento resulta indispensable para alcanzar la finalidad del contrato y, en esa medida, satisfacer el interés de la contraparte; estableciéndose como condición adicional para tal calificación que se haya contemplado en las Bases o en el contrato. En otras palabras, es aquella cuyo incumplimiento impide alcanzar la finalidad del contrato.*
> *(…)"*

Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes.

133. Por lo que, no habiéndose configurado el incumplimiento del PRIDER, en términos obligaciones esenciales, sobre el suministro del relleno tipo M8, no se cumple el requisito de antijuricidad.

134. Sin perjuicio de lo señalado, debemos precisar que, respecto del daño emergente, EL CONSORCIO afirmó que este se presenta en la diferencia comprobada entre el pago por los metrados realmente ejecutados y el pago realizado por el PRIDER. En ese sentido, mientras el PRIDER pagó S/ 1,144,192.66 (un millón ciento cuarenta y cuatro mil ciento noventa y dos y 66/100 soles)[16], lo cierto es que debió haber pagado S/ 1,582,402.90 (un millón quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos dos y 90/100 soles), por lo que el perjuicio asciende a S/ 438.209.90 (cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos nueve y 90/100 soles). No obstante, con ocasión del análisis realizado por la Árbitra Única de la Segunda Pretensión Principal, se determinó, entre otros, que EL CONSORCIO haya valorizado adecuadamente los metrados correspondiente al pago que reclama y que estos, además, cuenten con la conformidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el contrato. Por lo señalado, la Árbitra Única se remite a la argumentación ofrecida en aquella ocasión.

135. Como vemos, el daño reclamado por EL CONSORCIO no se configura, puesto que la -pretendida- existencia del perjuicio ascendente a S/ 438.209.90 (cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos nueve y 90/100 soles) no ha sido debidamente acreditado en el proceso. De hecho, debemos precisar que EL CONSORCIO no cumplió con adjuntar el medio probatorio que, según su demanda, permitiría acreditar dicho perjuicio[17]. En ese sentido, no es posible afirmar que exista el pretendido daño emergente.

136. En conclusión, atendiendo a que, como explicamos, la responsabilidad civil presupone la configuración de todos sus elementos en forma conjunta y a que no se configura la antijuridicidad ni, tampoco, el daño reclamado, no resulta posible asignar responsabilidad en el PRIDER.

137. Al respecto, debemos resaltar que carece de objeto pronunciarse respecto de los argumentos vertidos por EL CONSORCIO respecto del resto de elementos, puesto que, verificada la inexistencia de los elementos analizados, no existe posibilidad de que podamos determinar la existencia de responsabilidad civil respecto del PRIDER.

[16] Se deja constancia de que en el fundamento jurídico N° 14 de la pretensión bajo análisis EL CONSORCIO afirma que lo pagado asciende a S/ 1,444,192.66 (un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y dos y 66/100 soles). No obstante, de la lectura de la demanda en su integridad se aprecia que ello corresponde a un error tipográfico originado en el fundamento jurídico N° 10 del sustento de la Segunda Pretensión Principal, puesto que el cuadro presentado afirma que lo pagado por el PRIDER asciende a S/ 1,144,192.66 (un millón ciento cuarenta y cuatro mil ciento noventa y dos y 66/100 soles), lo que coincide con las operaciones aritméticas realizadas para justificar el monto reclamado por EL CONSORCIO, siendo que por error, en dicho párrafo (por primera vez) se comete el señalado error tipográfico y se confunde la cifra citada y se coloca -por error- el monto de S/ 1,444,192.66 (un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y dos y 66/100 soles).

[17] Al respecto, nos remitimos a lo explicado con ocasión del análisis de la segunda pretensión principal.

138. Por tanto, corresponde declarar infundada la pretensión subordinada a la segunda pretensión principal de la demanda interpuesta por el CONSORCIO.

d) Fundamentación de la Cuarta Cuestión Controvertida

139. El punto controvertido que se procede a analizar es el siguiente:

> **iv.** **Cuarta cuestión controvertida referida a la Tercera Pretensión Principal:**
> De no admitirse la Segunda Pretensión Principal ni la Pretensión Subordinada a la Segunda Pretensión Principal, que el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no determinar el metrado realmente ejecutado por el Consorcio Ayacucho en la prestación del servicio de extracción, apilamiento, transporte, conformación de enrocado y filtros en cuerpo de presa, incl. excavación para el cimiento, para la obra: construcción del sistema de irrigación -represa Pal/cea en el Distrito de Quinua -Huamanga -Ayacucho, conforme al sistema de contratación, hasta el 12 de diciembre de 2022 y, consecuentemente, si corresponde determinar el saldo económico pendiente de pago a favor del Consorcio.

140. A través de su Tercera Pretensión Principal, el CONSORCIO solicita que, en caso no se tutele la segunda pretensión principal, el Tribunal Arbitral determine el metrado realmente ejecutado por el CONSORCIO en la prestación del servicio de extracción, apilamiento, transporte, conformación de enrocado y filtros en cuerpo de presa, incl. excavación para el cimiento, para la obra: construcción del sistema de irrigación – represa Pallcca en el Distrito de Quinua – Huamanga – Ayacucho, conforme al sistema de contratación, **hasta el 12 de diciembre de 2022** y, consecuentemente, determine el saldo económico pendiente de pago a favor del Consorcio.

141. Como se indicó previamente en el análisis de la Segunda Cuestión Controvertida, de la lectura conjunta de la cláusula cuarta del Contrato y las Bases Integradas del Servicio, se estableció que la valorización del servicio estaría a cargo del Contratista, siendo responsabilidad del CONSORCIO la presentación de la documentación sustentatoria que acredite dicha valorización mensual del servicio efectuado de manera mensual, para su correspondiente conformidad y pago a cargo de la Entidad.

142. En esa línea, la Árbitra Única estima pertinente indicar que, tratándose de contratos de servicios, el marco normativo aplicable establece un procedimiento de recepción y conformidad regulado por el artículo 168 del RLCE, en los siguientes términos:

> ***Artículo 168. Recepción y conformidad***
> *168.1.* ***La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria.*** *En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección.*

168.2. ***La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.***
Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento.
168.3. La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación, o si se trata de consultorías, la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días.
168.4. ***De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación, o si se trata de consultorías, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días.***
Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.
168.5. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el numeral anterior.
168.6. Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general y/o consultorías manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.
168.7. ***Las discrepancias en relación a la recepción y conformidad pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de ocurrida la recepción, la negativa de esta o de vencido el plazo para otorgar la conformidad, según corresponda.***

143. De conformidad con lo expuesto, el marco normativo y contractual aplicable determina que la Entidad, específicamente a través de su área usuaria, es la responsable de la emisión de la conformidad de la prestación, estableciendo un plazo máximo para dicha actuación que no deberá exceder de los siete (07) días, y excepcionalmente, en los casos en que se requiera efectuar pruebas, de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario respectivo, en este caso del Residente de Obra y visto bueno de la Supervisión de obra, decretado por la Dirección de Infraestructura, de acuerdo a los numerales 7.7 y 7.8 de las Bases Integradas.

7.7 Conformidad de la Prestación
Será otorgado por el Residente de Obra y V°B° del Supervisor de Obra, decretado por la Dirección de Infraestructura y conforme lo dispone el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.8 Forma de Pago
La forma de pago será en PAGO PARCIALES O PERIODICOS, previa sustentación con documentos que acrediten dicha valorización mensual, previa presentación de documentos exigidos en el numeral 7.7 del presente.

Fuente: Bases Integradas que conforman el contrato.

144. La emisión de la conformidad de la prestación ha sido asignada contractual y legalmente al área usuaria de la Entidad. En ese sentido, la Árbitra Única considera que se encontraría impedida jurídicamente de suplir dicha función de comprobación y/o verificación de la prestación ejecutada por el Contratista, que involucra determinar la cantidad del cumplimiento de las condiciones realizadas en el servicio, conforme pretende el CONSORCIO, y que en virtud de la normativa aplicable es responsabilidad de la Entidad.

145. Por otro lado, la Árbitra Única considera que resulta atendible lo indicado por el PRIDER en lo que respecta, a que el Contratista no ha cuestionado las valorizaciones aprobadas y pagadas por la Entidad, y que en la demanda tampoco habría acreditado con medios probatorios lo solicitado.

146. En efecto, debe tenerse presente que el CONSORCIO ha reconocido haber valorizado el servicio en el mes de agosto, setiembre, octubre y noviembre de 2022[18], no verificándose que el demandante haya cuestionado la valorización o conformidad de la prestación mediante arbitraje, de acuerdo al numeral 168.7 del RLCE que establece lo siguiente:

> *168.7. **Las discrepancias en relación a la recepción y conformidad pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de ocurrida la recepción, la negativa de esta o de vencido el plazo para otorgar la conformidad, según corresponda.***

147. Por lo que, la valorización y pagos de los trabajos ejecutados por el CONSORCIO en los meses de agosto, setiembre, octubre y noviembre de 2022, se encontraría consentidos.

148. Por estas consideraciones, en observancia al marco legal y contractual aplicable, no corresponde declarar infundada la tercera pretensión principal de la demanda interpuesta por el CONSORCIO.

e) Fundamentación de la Quinta Cuestión Controvertida

149. El punto controvertido que se procede a analizar es el siguiente:

[18] De conformidad con el fundamento 12 del escrito de demanda, presentado por el CONSORCIO.

v.	**<u>Quinta cuestión controvertida referida a la Cuarta Pretensión Principal:</u>** Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no considerar como justificado los retrasos incurridos por el consorcio en la prestación del servicio y, consecuentemente, ordenar a PRIDER, la devolución del monto retenido por la Entidad como garantía de fiel cumplimiento para la ejecución del Contrato N° 032-2022-GRAPRIDER/DG.

150. Respecto al presente punto controvertido, el CONSORCIO sustenta su posición indicando que el incumplimiento de sus obligaciones se encontraría debidamente justificado, dado que al no tener el material de tipo M8, no era posible continuar con las labores en campo. En ese sentido, alega que, a través de la Carta de apercibimiento, presentado a la Entidad el 05 de diciembre de 2022, advirtió sobre el incumplimiento de la obligación esencial de la Entidad de suministrarnos el material de tipo M8, comunicándole que no era posible continuar con la prestación del servicio.

151. En ese sentido, es clara la posición del CONSORCIO respecto a la alegación de la existencia de una causa justificada debido a que el PRIDER le exigió ejecutar el contrato incorporando el servicio de suministro de material M8, pese a que dicho aspecto no estuvo considerado en las Bases Integradas, que constituyen las reglas definitivas de la contratación, ni tampoco en su oferta.

152. Por su parte, el PRIDER no ha efectuado mayor fundamentación sobre este extremo controvertido, limitándose a señalar que corresponde la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento ante la resolución del contrato efectuada por dicha parte.

153. Respecto a la consideración del atraso incurrido en el servicio como justificado, se estima pertinente indicar que el marco normativo aplicable al contrato regula la penalidad por mora en el artículo 162 del RLCE, la misma que aplica frente al retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, por cada día de atraso, según la fórmula establecida en dicho dispositivo normativo:

> ***Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación***
> *162.1. En caso de retraso **injustificado** del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:*
>
> $$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$
>
> *Donde F tiene los siguientes valores:*
> *a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F 0.40.*

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías:
F = 0.25
B.2) Para obras: F = 0.15

162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso.
162.3. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la Entidad puede establecer en los documentos del procedimiento de selección la penalidad a aplicarse.
162.4. Para los supuestos que por la naturaleza de la contratación, la fórmula indicada en el presente artículo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial puede establecer fórmulas especiales para el cálculo de la penalidad por mora.
162.5. El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

154. Es importante señalar que, la aplicación de la penalidad por mora supone la verificación del supuesto penalizable, esto es ante el retraso **injustificado** del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, siendo la determinación de este aspecto necesario para su debida aplicación, conforme con el criterio reconocido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), y con el cual comparte la Árbitra Única.

155. En ese sentido, se resalta la importancia que tiene el análisis del criterio de imputabilidad sobre el incumplimiento verificado por el Contratista respecto a sus obligaciones, de manera que solo corresponderá la aplicación de la penalidad por mora solo cuando no exista una situación que objetivamente justifique que el atraso no es imputable al Contratista.

156. De otra parte, es preciso indicar que el numeral 162.5 del RLCE, reconoce la posibilidad de justificar el retraso en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, estableciendo que podrá efectuarse mediante cualquiera de las formas siguientes: (i) Cuando exista una solicitud de ampliación de plazo, debidamente aprobada; o (ii) Cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable, precisando que en este caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

162.5. El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

157. En el presente caso, se aprecia que el CONSORCIO ha sustentado su pretensión únicamente en base a la argumentación jurídica vinculada a que el material M8 no comprendía parte de sus obligaciones contractuales; sin embargo, dicha afirmación a criterio de la Árbitra Única no resulta suficiente para demostrar de forma objetiva que nos encontremos ante un supuesto de retraso justificado.

158. Tal como se mencionó anteriormente, de acuerdo con el marco legal aplicable, existen dos maneras de justificar el retraso en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato. Respecto a la primera de ellas, se indica que esta se sustenta en la actuación de la Entidad de reconocer una ampliación de plazo contractual solicitada en base a una causal y procedimiento contemplado en el artículo 158 del RLCE. Sin embargo, de los actuados del caso, no se verifica que el PRIDER haya aprobado una solicitud de ampliación de plazo al CONSORCIO.

159. Por otro lado, respecto a la segunda forma de justificación del retraso, debe indicarse que conforme al numeral 162.5 del RLCE, ésta exige la acreditación sustentada del Contratista, de modo objetiva e indubitable, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Si bien la normativa aplicable no ha regulado un procedimiento específico, formalidades o plazos, a fin de calificar un retraso como justificado[19], debe indicarse que el CONSORCIO no ha acreditado ni sustentado de forma objetiva que el retraso incurrido se haya debido a la imposibilidad de continuar los trabajos debido a que no contaba con el material de tipo M8. Es así que no se cuentan con elementos suficientes que permitan establecer al tribunal arbitral que el CONSORCIO actuó con diligencia ordinaria ejecutando las prestaciones a su cargo, que no encontraban afectadas con el suministro del material de relleno tipo M8, pues no se ha sustentado en los actuados el flujo de avance diligente del servicio no vinculado al material M8.

160. Por el contrario, de la Valorización N° 4 presentada en el proceso, consta únicamente que el CONSORCIO habría valorizado un 38.66% del contrato, tal como se muestra a continuación:

[19] De acuerdo con el numeral 2.1 de la Opinión N° 012-2021/DTN.

RESUMEN VALORIZADO DE OBRA N° 04

FUNCION 019 SALUD

MEGA: CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTRACCION, APILAMIENTO, TRANSPORTE, CONFORMACION DE ENROCADO Y FILTRO DE CUERPO DE PRESA, INCL. EXCAVACION PARA EL CIMIENTO, PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE IRRIGACION - REPRESA PALLCCA EN EL DISTRITO DE QUINUA -HUAMANGA-AYACUCHO"

FUNCION

FECHA

PRESUPUESTO TI S/3,708,125.19

FECHA DE INICIO 16/08/2020

FECHA TERMINO 19/11/2022

MES SETIEMBRE 2022

UBICACIÓN

DEPARTAM : AYACUCHO

PROVINCIA : HUAMANGA

DISTRITO : QUINUA

LUGAR : PALLCCA

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO COSTO DIRECTO S/.	% DE AVANCE FISICO EJECUTADO						SALDO	
			ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO			
			VALORIZADO S/.	%	VALORIZADO S/.	%	VALORIZADO S/.	%	VALORIZADO S/.	%
01	COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TEC.	3,708,125.19	855,807.35	23.09%	577,005.87	15.57%	1,432,813.22	38.66%	2,273,311.96	61.34%
6.0	TOTAL DE COSTO DIRECTO	3,708,125.19	855,807.35	23.09%	577,005.87	15.57%	1,432,813.22	38.66%	2,273,311.96	61.34%

MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA

De acuerdo a la valorización del mes de noviembre del 2022 el monto a pagar al contratista es la suma de S/. 577,005.87 (QUINIENTOS SETENTAISIETE MIL CEROCERO CINCO CON 87/100 SOLES), que representa el 15.57% del avance fisico.

OBSERVACIONES:

1. Que a la fecha se tiene dificultades en la producción del M 8 los cuales están generando el retraso del avance fisco para lo cual se presentaron documentos a la entidad para dar las soluciones pertinentes.

161. Debe tenerse presente que de acuerdo con el numeral 32.6 de la LCE: "El contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecución del contrato. Para ello, debe realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos públicos previstos."

162. En virtud de lo señalado, es responsabilidad de contratista actuar con la diligencia requerida para el cumplimiento de su obligación; pues solo de esa forma, no será imputable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, conforme lo establece el artículo 1314 del Código Civil:

> *Inimputabilidad por diligencia ordinaria*
> *Artículo 1314°.- Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.*

163. En el caso de análisis, consta de los medios probatorios actuados, que el 05 de diciembre de 2022, el CONSORCIO comunicó al PRIDER que no era posible continuar con la prestación del servicio; no obstante, la Árbitra Única advierte que a dicha fecha (05 de diciembre de 2022) ya se habría superado el plazo previsto para la ejecución del servicio, el cual consideraba como fecha de término el 19 de noviembre de 2022.

164. Debe tenerse en cuenta, que el contratista es responsable de realizar correctamente

la totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecución del contrato en el plazo previsto en el contrato, lo que comprende realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia para la consecución de los objetivos públicos[20]. Asimismo, de encontrarse disconforme con cualquier decisión surgida en la ejecución del contrato, el contratista tiene la facultad de iniciar los mecanismos de solución de controversias previstos en contrato y en la ley, dentro del plazo de caducidad correspondiente.

165. Por lo que, de acuerdo con los hechos del caso, el derecho aplicable y la valoración de los medios probatorios admitidos, se verifica que no encuentra probado de forma objetiva que el retraso incurrido por el CONSORCIO no le sea imputable.

166. Respecto al segundo extremo solicitado por el CONSORCIO relacionado a la devolución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, la Árbitra Única estima pertinente a lo regulado en el marco contractual y legal aplicable.

167. De acuerdo con el artículo 149 del RLCE, la Garantía de Fiel Cumplimiento se constituye por el diez por ciento (10%) del monto del contrato original y debe mantenerse vigente **hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del Contratista**, en el caso de servicios en general:

> *Artículo 149. Garantía de fiel cumplimiento*
>
> *149.1. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.* ***Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general****, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras.*
>
> (…)

168. Adicionalmente, el numeral 149.4 del RLCE contempla que, en los casos de contratos de servicios en general, cuando las Entidades celebren contrato con micro y pequeñas empresas, éstas últimas podrán otorgar la garantía de fiel cumplimiento equivalente al diez por ciento (10%) del contrato original mediante retenciones a los pagos, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo:

> *Artículo 149. Garantía de fiel cumplimiento*
>
> *(…)*

[20] De acuerdo con el numeral 32.6 del RLCE.

149.4. ***En los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, así como en los contratos de consultoría en general, de ejecución y consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad.***

En el caso de los contratos para la ejecución de obras, tal beneficio solo procede cuando: a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada; b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.

149.5. La retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

(…)

169. En atención a lo expuesto, en la cláusula sétima del contrato, se estableció que la retención por garantía de fiel cumplimiento ascendente a la suma de S/ 370,612.519 soles se realizaría durante la mitad del número total de pagos a realizarse en el servicio, estableciendo que dicha retención sería devuelta a la finalización del mismo:

> CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS
> EL CONTRATISTA, por encontrarse dentro del régimen de la Micro y Pequeña Empresa, conforme acredita con la copia del reporte del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE, según CARTA N° 002-2022-CONS-AYACUCHO/RC, solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto contractual por garantía de fiel cumplimiento, el cual asciende a la suma de S/ 370,612.519 (trescientos setenta mil seiscientos doce con 519/100 soles), que deberá efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

170. Sobre el particular, como lo ha expuesto el Organismo Técnico Especializado del OSCE en distintas opiniones15, "*las garantías que se exigen en el marco de los procesos de contratación pública cumplen una doble función: compulsiva y resarcitoria. Son compulsivas, puesto que pretenden compeler u obligar al contratista a cumplir con todas sus obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de ejecutar las garantías presentadas por este; asimismo, son resarcitorias, puesto que pretenden, con su ejecución, indemnizar a la Entidad por los eventuales daños que hubiera sufrido debido al incumplimiento del contratista*" [sic][21]

171. De acuerdo con el marco contractual y legal aplicable, se desprende que el monto

[21] De acuerdo a la Opinión N° 125-2019/DTN.

retenido en calidad de garantía de fiel cumplimiento tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONSORCIO, con lo cual, ante la verificación de una situación de incumplimiento de parte del Contratista, la Entidad cuenta con la facultad de ejecutar la garantía en mención y compensar los montos que correspondan.

172. Por lo que, siendo que, en el caso de autos no se cuenta con la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, el Tribunal Arbitral unipersonal considera que no resulta procedente el pedido del CONSORCIO de devolver el monto retenido como garantía de fiel cumplimiento. Máxime, si no se tiene plena seguridad de que no existe un saldo a favor de la Entidad que corresponda por aplicación de penalidades, atendiendo a que mediante la Carta Notarial N° 072-2022-GRA-GG/PRIDER-DG de fecha 14 de noviembre de 2022, la Entidad dejó constancia de su correspondencia.

173. Por estas consideraciones, en observancia al marco legal y contractual aplicable, corresponde declarar infundada la cuarta pretensión principal de la demanda interpuesta por el CONSORCIO.

f) **Fundamentación de la Quinta Cuestión Controvertida**

174. El punto controvertido que se procede a analizar es el siguiente:

> **v. <u>Quinta cuestión controvertida referida a la Cuarta Pretensión Principal:</u>**
> Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no considerar como justificado los retrasos incurridos por el consorcio en la prestación del servicio y, consecuentemente, ordenar a PRIDER, la devolución del monto retenido por la Entidad como garantía de fiel cumplimiento para la ejecución del Contrato N° 032-2022-GRAPRIDER/DG.

175. El CONSORCIO solicita que el PRIDER sea condenado al pago de la totalidad de gastos arbitrales irrogados en el proceso, dado que se ha negado de forma injustificada a pagar por la prestación efectivamente realizada.

176. Por su parte, el PRIDER señala que corresponde que se conmine a la demandante el pago íntegro de las costas y costos, debido a que la demanda carece de sustento factico y jurídico.

177. En tal sentido, el Tribunal Arbitral Unipersonal procede a evaluar la distribución y asunción de los costos del arbitraje.

178. Sobre el particular, el artículo 71 del Reglamento del CENTRO, establece que costos del arbitraje comprenden: (a) Los gastos administrativos del Centro, que está compuesto por la tasa de presentación de la solicitud de arbitraje, la tasa de designación del árbitro y la tasa administrativa del Centro; (b) Los honorarios de los árbitros; (c) Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por los árbitros, conforme a este Reglamento; (d) Los honorarios razonables de las defensas de las partes y; (e) Otros gastos razonables derivados de las actuaciones arbitrales. La determinación de los costos y demás cuestiones referidas a los gastos administrativos del CENTRO son de potestad exclusiva del CENTRO.

179. Por su parte, el artículo 73 de la Ley de Arbitraje contempla que, a falta de acuerdo, el Tribunal Arbitral podrá determinar los costos del arbitraje, estando facultado a distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso:

> *Artículo 73.- Asunción o distribución de costos.*
> *1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.*
> *(…)*

180. En el presente caso de la revisión del convenio arbitral celebrado entre las partes, se advierte que las partes no convinieron nada con relación a los costos del arbitraje, por lo que corresponde al Tribunal Arbitral Unipersonal determinar, de manera discrecional y de forma razonable, la asunción o costos del arbitraje.

181. Para dicho propósito, la Árbitra Única tiene en cuenta el resultado del presente arbitraje, pero también la conducta procesal mostrada por cada parte. En ese sentido, se determina que el PRIDER asuma el 80% de los costos del arbitraje conformados por los gastos administrativos del Centro y los honorarios de la Árbitra Única.

182. Se estima pertinente indicar que la secretaria arbitral determinó los gastos administrativos del Centro y los honorarios de la Árbitra Única, conforme al detalle siguiente:

Concepto	Monto
Honorarios de la Árbitra Única	S/ 17, 749.36 más impuestos de ley.
Gastos administrativos del Centro	S/ 10, 380.24 más impuestos de ley.

Fuente: Liquidación de gastos arbitrales notificada a las Partes mediante Resolución N° 1.

183. En virtud de lo señalado, considerando que el CONSORCIO asumió el 100% de los costos del arbitraje, el PRIDER deberá reembolsarle el 80% de estos costos, esto es S/8,304.19 más IGV por gastos administrativos del CENTRO y S/14,199.49 por honorarios del Tribunal Arbitral Unipersonal, más el impuesto de ley.

184. Con relación a los gastos de abogados y otros gastos razonables derivados de las actuaciones arbitrales, la Árbitra Única estima razonable que cada una de las partes asuma los gastos incurridos de su defensa legal, así como los demás gastos que hayan realizado con motivo de fundamentar sus posiciones en el presente arbitraje.

185. Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar **FUNDADA EN PARTE** la quinta pretensión principal formulada por el CONSORCIO.

III. DECISIÓN:

En atención a lo expuesto, se estima pertinente manifestar que el Tribunal Arbitral Unipersonal ha ejercido su cargo con estricta imparcialidad e independencia, no habido sido objeto de conflicto de interés, coacción o cualquier otro acto que menoscabe sus atribuciones; en ejercicio de la función de que las Partes, habiendo desarrollado las actuaciones arbitrales en observancia de los principios que rigen la actuación arbitral y conforme a las Reglas y Reglamento del Centro.

Por tanto, en ejercicio de la función que las partes y la Constitución Política del Perú le han conferido, el Tribunal Arbitral Unipersonal resuelve las controversias puestas a su conocimiento con el presente Laudo parcial, conforme a lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la primera pretensión principal de la demanda, de acuerdo con los fundamentos expuestos en el presente laudo arbitral; en consecuencia, **SE DECLARA** inválida e ineficaz la resolución parcial del Contrato N° 032-2022-GRA-PRIDER/DG, efectuado por la Entidad mediante Carta Notarial N° 80-2022-GRA-GG/PRIDER-DG, de fecha 12 de diciembre de 2022.

SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADA la segunda pretensión principal de la demanda, de acuerdo con los fundamentos expuestos en el presente laudo arbitral.

TERCERO: DECLARAR INFUNDADA la pretensión subordinada a la segunda pretensión principal, de acuerdo con los fundamentos expuestos en el presente laudo arbitral.

CUARTO: DECLARAR INFUNDADA la tercera pretensión principal de la demanda, de acuerdo con los fundamentos expuestos en el presente laudo arbitral.

QUINTO: DECLARAR INFUNDADA la cuarta pretensión principal de la demanda, de acuerdo con los fundamentos expuestos en el presente laudo arbitral.

SEXTO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la quinta pretensión principal de la demanda formulada por el CONSORCIO AYACUCHO, debiendo el PRIDER asumir el 80% de los gastos arbitrales liquidados en el arbitraje.

En consecuencia, **i)** Se **ORDENA** al PRIDER reembolsar al CONSORCIO la suma de S/8,304.19 más IGV por gastos administrativos del CENTRO y S/14,199.49 por honorarios del Tribunal Arbitral Unipersonal, más el impuesto de ley. y; (ii) Se **DISPONE** que corresponde a cada parte asumir sus respectivos gastos incurridos por concepto de defensa legal, así como los demás gastos que hayan realizado con motivo de fundamentar sus posiciones en el presente arbitraje.

SEXTO: REGISTRAR el presente laudo parcial en el SEACE, de conformidad con lo establecido en el numeral 238.1 del artículo 238 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

María del Carmen Padilla Ortega
Árbitra Única

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD